

SÓCRATES: vivió en los años 469 a 399 (a.C.). No dejó obra escrita alguna, y además se carecen de datos biográficos ciertos. Fue el creador de una corriente que aún perdura. *"Como es sabido, Sócrates provoca a sus jueces. Parece que busca el martirio. Y con ello concuerda que se niega a huir de la cárcel. Sócrates se evade éticamente de un callejón sin salida intelectual. En efecto, beber la cicuta era la única manera por la cual pudo convencer a los demás que realmente creía en un orden objetivo de valores y de conceptos del cual ningún conocimiento seguro había sabido brindar. Sócrates no escribía sus teorías; pero murió por ellas; y ello es así, porque no sabía qué escribir, pero sí sabía por qué morir"*¹⁶.

Su discípulo PLATÓN (427 a 347 a.C.), por el contrario, deja gran cantidad de obras escritas, las más importantes para nuestro tema son *La República* y *Las Leyes*.

Platón entiende que la justicia es una virtud universal, y ésta consiste en que cada hombre confíe su actividad estrictamente al desempeño de las funciones específicas de acuerdo a la división de trabajo que surge como natural en atención a las distintas clases sociales.

Nos dice que los hombres son naturalmente distintos, por lo que su actividad y ubicación en la estructura social debe estar de acuerdo a la naturaleza particular de cada uno. Así, existen tres clases, la primera, son los artesanos, labradores, comerciantes, los que deben realizar todas las tareas para las cuales tienen capacidad natural y abstenerse de aquellas otras; para las cuales no han sido hechos. Ellos pueden poseer bienes y formar familia.

La segunda, son los guardianes o guerreros, y por último la tercera, la de los magistrados. Ambos sectores, no podían poseer bienes propios ni familia. Cada individuo en esta sociedad debía subordinar sus propios deseos al interés y beneficio del conjunto.

La justicia consiste entonces —según Platón— en que cada uno realice de la manera más acabada posible su propia naturaleza, para el beneficio y armonía del conjunto.

"Los que formáis parte de la ciudad sois, pues, hermanos, pero el dios que los ha formado hizo entrar oro en la composición de aquellos de vosotros que sois propios para gobernar a los demás; por lo tanto, son éstos los más nobles; hizo entrar plata en la composición de los auxiliares, y el hierro y bronce en la de los labradores y demás artesanos. Como todos tenéis un origen común, vuestros hijos serán semejantes a vosotros pero puede suceder que de un ciudadano de la especie del oro proceda un

¹⁶ GOLDSCHMIDT, *op. cit.*, pág. 473.

*vástago de la especie de la plata, o que uno de la especie de la plata tenga un descendiente de la del oro, y que lo mismo ocurra con los dos metales restantes. Ahora bien, el dios ordena sobre todo a los gobernantes que presten especial atención al metal con que se haya forjado el alma de sus descendientes, y si sus propios hijos tuvieran alguna mezcla de bronce o hierro deben, pues, los gobernantes, sin honrarlos más de lo que conviene a su naturaleza, obrar sin conmiseración alguna y relegarlos a la condición de los artesanos o labradores; por el contrario, si de éstos nacen hijos con mezcla de oro o de plata, elevarlos en el primer caso al rango de los destinados a guardianes de la ciudad y de auxiliares en el segundo, porque hay un oráculo según el cual la ciudad perecerá cuando sea guardada por el hierro y el bronce"*¹⁷.

Para concluir este rápido repaso sobre las ideas de Platón, podemos afirmar, que éste consideraba que la justicia consiste en que cada uno realice de la mejor manera posible, la función para la que fue dotado por la naturaleza. De manera tal que cada uno colabore desde su lugar a la felicidad del conjunto, lo que implica estar en presencia de una comunidad armónica.

El discípulo de Platón, ARISTÓTELES, vivió en los años 384 a 322 (a.C.). Al igual que Platón, dejó escritas gran cantidad e importantes obras. A nosotros nos interesa particularmente la *Ética a Nicómaco* y *La Política*.

Consideraba al hombre como *zoon politikón* (animal político) y al Estado como natural al hombre. La existencia del Estado y de los distintos tipos de gobiernos que cada sociedad pueda darse encuentran su legitimación última en la promoción del bienestar general.

Para evitar todo tipo de excesos en el gobierno (favoritismo, arbitrariedad, etc.) debe éste basarse y regirse por la ley.

*"Es pues más útil que la ley mande, que no cualquier particular ciudadano... El que ordene, pues, que la ley sea la que gobierne, parece que dispone que el mismo dios gobierne, y también las leyes. Pero el que ordene que el hombre mande, dispone también que la bestia fiera sea la que regule la vida, porque en tal cuenta tenemos que tener al apetito, y la saña pervierte a los magistrados y aun a los mejores de los hombres. Por esto, la ley no es otra cosa que un entendimiento libre de apetitos"*¹⁸.

La justicia consiste, para Aristóteles, en un patrón objetivo de igualdad. Los iguales deben ser tratados de igual manera. Y, además, la justicia

¹⁷ PLATÓN, *La República*, cit., pág. 229.

¹⁸ ARISTÓTELES, *Política*, Orbis, Madrid, 1985, pág. 158.

no es simplemente una virtud particular, sino que se corporiza en una especie de suma total de todas las virtudes.

*"Llamamos justicia aquel hábito y costumbre que hace prontos a los hombres en el hacer cosas justas, y por el cual los hombres obran justamente y aman las cosas justas. Y de la misma manera la injusticia aquella costumbre que induce a los hombres a hacer agravios y a querer lo que no es justo... Parece pues, que así el que traspasa las leyes, como el que codicia demasiado, y también el que no guarda igualdad en el trato de las cosas, y lo justo será lo que es conforme a la ley y a la igualdad, y lo injusto lo que es contra la ley y desigualdad... De manera que la justicia no es una sola especie de virtud, sino una suma de virtudes. Ni su contraria la injusticia es una especie de vicio, sino una suma de todo género de vicios."*¹⁹

Distingue dos clases de justicia: la distributiva, que consiste en asignar a cada ciudadano los derechos públicos y privados que le corresponden en virtud de su contribución al bien común. Significa que la atribución es proporcional al mérito de cada uno, por lo que la igualdad planteada es proporcional al mérito de cada uno.

*"De manera que lo justo es cosa que consiste en proporción... Es, pues, esta manera de justo, cosa que consiste en proporción, y esta manera de injusto, cosa que no tiene proporción... Porque la justicia que consiste en la distribución de cosas comunes siempre se ha de tratar por la proporción que habremos dicho, pues la repartición de intereses comunes, si se hiciere, se ha de hacer por la misma cuenta y proporción que se hace el repartimiento del tributo, y la injusticia que esta justicia contradice, es la fuera de proporción."*²⁰

La segunda clase es la llamada retributiva o correctiva. Aquí se plantea como objetivo primordial mantener la igualdad.

"Pero lo justo que consiste en los contratos, es cierta igualdad, y lo injusto desigualdad... La ley solamente tiene en cuenta la diferencia del daño, y quiere reducir al que hace injuria y al que la padece. Y si de dos el uno hizo daño y el otro lo recibió, el juez pretende tal cosa como aquella, como injusta y desigual reducirla a igualdad... Porque lo que toma más del bien y menos del mal es ganancia, y lo que al contrario desto es daño o perjuicio, de las cuales dos cosas es el medio lo igual, que es lo que llamamos justo. De manera que lo que corrige y enmienda los contratos, es lo justo y el medio entre el perjuicio y la ganancia. Y así, cuan-

¹⁹ ARISTÓTELES, *Ética*, págs. 153-154.

²⁰ ARISTÓTELES, *Ética*, págs. 159 a 161.

*do dos contienden sobre esto, luego acuden al juez, e ir al juez es lo mismo que ir a lo justo. Porque el juez no se pretende que es otra cosa que una justicia que habla. Y buscan un juez medio, y aún algunos los llaman medianeros, porque si alcanzan el medio alcanzan lo que es justo. De manera que lo justo es una medianía, pues lo es el juez mismo que lo juzga. Ni hace otro el juez sino igualar, de la misma manera que una línea en dos partes dividida, tanto cuanto más la una parte excede de la mitad, le quita y lo añade a la otra parte. Pero cuando el todo estuviere en dos iguales partes repartidos, entonces dicen que tienen cada uno lo suyo... De manera que lo justo es el medio entre cierta pérdida y ganancia"*²¹.

En resumen, la justicia distributiva realiza el reparto de bienes en proporción a los méritos realizados por cada uno. Y la justicia retributiva o correctiva regula aquellas relaciones de cambio, tanto en las contraprestaciones recíprocas en los contratos, como las que surgen de los delitos y cuasidelitos, donde pretende mantener la igualdad entre las partes.

Los estoicos, escuela fundada por ZENÓN (350 a 260 a.C.). Nos plantea que la libertad que surge de la supresión de las pasiones no puede ser destruida por poder alguno.

Esta corriente estructura una sociedad cosmopolita sustentada por la igualdad de todos los hombres. En virtud de esa igualdad, se logra un estado universal sobre el que puede erigirse una convivencia armónica.

Esta sociedad universal *"Había existido en un estadio muy primitivo de la sociedad humana. En esa 'edad de oro' de la humanidad se había realizado completamente el ideal absoluto del derecho natural. Todos los hombres eran libres e iguales. No había división de los hombres en clases o nacionalidades. Eran desconocidas las instituciones de la propiedad privada y la familia. No existían la esclavitud ni ninguna otra forma de dominio del hombre por el hombre. Todos los hombres gozaban en común de todas sus posesiones y bienes, y vivían como verdaderos hermanos, bajo la guía de la razón... La razón como fuerza universal que penetra todo el cosmos era considerada por los estoicos como la base del derecho y la justicia. La razón divina—decían— mora en todos los hombres, de cualquier parte del mundo, sin distinción de raza ni nacionalidad. Hay un derecho natural común, basado en la razón, que es universalmente válido en todo el cosmos"*²².

En Roma, si bien no hubo una filosofía original, fueron los primeros en estructurar un sistema jurídico.

²¹ ARISTÓTELES, *Ética*, págs. 161 a 163.

²² BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., págs. 130-131.

Sobre el *ius naturale* dice: "Para Paulo es lo que siempre es justo y conveniente; para Ulpiano es lo que la naturaleza ha inculcado a todos los seres animados como la unión del macho y de la hembra, la procreación y la educación de los hijos; por último, en las Instituciones de Justiniano tenemos, con fuerte influencia de la doctrina cristiana: el derecho natural, que en todos los pueblos se observa por igual, establecido por una cierta providencia divina, siempre permanece firme e inalterable"²³.

CICERÓN (106 a 46 a.C.) "como los estoicos identificaba naturaleza y razón y suponía que la razón era el poder dominante del universo. El verdadero derecho —dijo— es la recta razón, conforme a la naturaleza; es de aplicación universal, inmutable y eterna; llama al hombre al bien con sus mandatos y lo aleja del mal mediante sus prohibiciones... Para él la justicia era emanación del derecho natural"²⁴.

En la Edad Media se produce la dualidad entre el Estado y la Iglesia. El más importante autor que resulta de la Patrística es SAN AGUSTÍN (354 a 430), que nos plantea una clara división entre la *Civitas Dei* y la *Civitas Terrena*. La ciudad terrena, con todas sus instituciones es el resultado del pecado. Antes no existían ni gobiernos, ni señorios, ni propiedad, etcétera. Este criterio culmina en la convicción de que la justicia plena sólo se realizará en la *Civitas Dei*, mientras tanto, "El derecho positivo debe tratar de llenar las demandas de la ley eterna. Si contiene disposiciones claramente contrarias a la ley de Dios, esas normas no tienen vigencia y no deben ser obedecidas. Pero a pesar de sus esfuerzos por realizar los postulados de la ley eterna, la ley terrena, que es una transacción con la realidad, no logrará nunca la perfección de aquélla. En algún tiempo venidero —esperaba San Agustín— la *Civitas Terrena* —la comunidad política mundana— será reemplazada por la *Civitas Dei* —la ciudad de Dios—. En esa comunidad que es la de todos los fieles y creyentes, reinará eternamente la ley de Dios"²⁵.

En la Escolástica, por su parte, sobresale SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), quien estructura un imponente sistema intelectual, es el que fusiona el pensamiento cristiano con el pensamiento aristotélico. De allí surge una reivindicación de la ciudad terrena, considerándola de la esencia propia del hombre, y no como consecuencia de su pecado. Y, coincidía con San Agustín en subordinar el Estado a la Iglesia.

²³ LA PIEZZA, E., *op. cit.*, pág. 17.

²⁴ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 134.

²⁵ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 145.

Santo Tomás distingue cuatro tipos de leyes: la *lex aeterna*, la *lex naturalis*, la *lex humana* y la *lex divina*.

La ley eterna es la misma razón del universo, que existe en el ser supremo (Dios). Es la divina sabiduría que gobierna todo el universo. Los seres humanos no pueden conocer plenamente este tipo de ley, pero sí participar en alguna medida de ella a partir del segundo tipo: la ley natural, la que consiste en el medio que tienen los hombres para penetrar en las intenciones de Dios. De ello surge la distinción entre el bien y el mal. Dado lo abstracto de la ley natural, se requieren mayores precisiones, que la aporta la ley divina que surge de las Sagradas Escrituras. Por último, la ley humana es creada por la voluntad del soberano, y así la define: "De las cuatro conclusiones establecidas puede colegirse una definición de la ley: la ley no es más que una prescripción de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad"²⁶.

También nos aclara los límites en que debe moverse la voluntad para que ésta se constituya en ley: "La razón puede, ciertamente ser movida por la voluntad como queda dicho; pues, por lo mismo que la voluntad apetece el fin, la razón impera acerca de los medios que a él conducen. Sin embargo, para que la voluntad, al apetecer esos medios tenga fuerza de ley, es necesario que ella misma sea regulada por la razón. Y así ha de entenderse el que la voluntad del príncipe se constituya en ley. De otro modo no sería ley, sino iniquidad"²⁷.

Por último, nos plantea de conformidad con Aristóteles que la ley injusta no vincula, no obliga a la voluntad del hombre. "Así lo enseña Santo Tomás: en cuanto a lo segundo hay que decir que la ley humana, en tanto tiene razón de ley, en cuanto que es conforme a la recta razón, y según esto es manifiesto que deriva de la ley eterna. Por el contrario, cuando una ley está en contradicción con la razón, se llama ley injusta, y así no tiene razón de ley; sino más bien se convierte en un acto de violencia"²⁸.

La Edad Media se caracteriza por la dualidad establecida entre el Estado y la Iglesia. Esta situación lentamente se modifica hasta transformarse en un trinomio con la irrupción del individuo. El pacto social, como sustento de la sociedad y de sus instituciones, se basa en la decisión de cada individuo, y así marcará a toda la época con un sello indeleble de profundo individualismo.

²⁶ SANTO TOMÁS DE AQUINO, *Summa Teológica*, Q. 90, art. 4.

²⁷ SANTO TOMÁS DE AQUINO, *Summa...*, cit., Q. 90, art. 1.

²⁸ Encíclica *Pacem in Terris*, nro. 51.

*"Desde otro punto de vista la Edad Moderna empieza con Colón. El descubridor de América es la primera persona que realiza una empresa basada en la fe en el acierto de leyes científicas. La razón de la fe es reemplazada por la fe en la razón, o la fe como razón es sustituida por la fe en la razón"*²⁹

MAQUIAVELO (1469-1527) plantea como objetivo la gloria del Estado, la omnipotencia estatal, y a tal fin se encuentran subordinados todos los principios éticos y morales. No duda en utilizar la traición y la violencia. El fin: la omnipotencia del Estado, justifica los medios que deban emplearse.

BODINO (1530-1597) desarrolla su propia teoría sobre la soberanía (vid., Cap. III). Al Estado lo veía como un poder único e indivisible. Un poder soberano que surge de la facultad de hacer las leyes y ponerlas en práctica, además de exigir y obligar su cumplimiento, sin que por ello se encuentre sometido a ellas. Es decir, dicta las leyes que obligan a los súbditos, pero el Estado no se encuentra, a su vez, obligado por las leyes por él dictadas (vid., Inviolabilidad, Cap. II).

GROCIO (1583-1645) coincide con Aristóteles en cuanto a la sociabilidad esencial del hombre. Separa la ciencia del derecho de la teología y de la religión, de lo que concluye en la existencia de un derecho natural conforme a la propia naturaleza del hombre. Por lo tanto, la existencia de este derecho natural no requiere necesariamente la existencia de la divinidad.

*"Hay una sociabilidad innata en los seres humanos que les permite convivir pacíficamente en sociedad. Todo lo que era conforme a ese impulso social y a la naturaleza del hombre como ser racional, era bueno y justo; todo lo que se opusiese —perturbando la armonía social— era malo e injusto. Grocio definía al derecho natural como un dictado de la recta razón que indica que un acto, según sea o no conforme a la naturaleza racional y social, tiene una cualidad de necesidad moral o de bajeza moral"*³⁰

Aquí comienza a observarse el desarrollo de los primeros planteos individualistas, que orientarán a toda esta época.

Las bases del derecho natural planteadas por Grocio son: respeto de la esfera de derechos de los demás y el principio *pacta sunt servanda*.

Finalmente, el origen del Estado lo encuentra en un pacto, por el cual los particulares transferían el poder a un soberano.

²⁹ GOLSCHMIDT, op. cit., pág. 477.

³⁰ BODENHEIMER, E., Teoría..., cit., pág. 155.

HOBBS (1588-1679), al contrario de Grocio, cree que el hombre es un ser esencialmente antisocial, el estado natural del hombre es aquél en que se da una guerra de todos contra todos *bellum omnium contra omnes*. El hombre para esta corriente es naturalmente un lobo dispuesto a disputar lo que fuere al resto de los hombres. *"Hobbes llamó derecho natural al cuerpo de principios que la razón humana imaginó para hacer la vida pacífica y segura. El derecho natural que pudo definir es el dictado de la recta razón que hay en nosotros, acerca de aquellas cosas que han de hacerse u omitirse para la conservación constante de la vida y los miembros"*³¹

Plantea la necesidad del pacto social, por el cual los hombres transfieren absolutamente todos sus derechos a favor del soberano. El poder del Estado así visto no encuentra límite alguno, salvo los límites que le impone los principios del derecho natural.

Ya con Hobbes el individualismo se acentúa y cobra la configuración que la corriente liberal en los próximos siglos delinea concretamente.

SPINOZA (1632-1677) sigue la línea de Hobbes, pero se diferencia con éste en el planteo de la libertad. Considera que la libertad es la más alta finalidad del gobierno.

PUFENDORF (1632-1694) es uno de los que ha sistematizado al derecho natural. Comienza por separar el Derecho de la religión; y, dentro del ámbito del Derecho, reconoce la existencia de uno positivo y otro natural. El derecho natural tiene primacía sobre el derecho positivo y éste debe atenerse a aquél.

El derecho natural tiene los siguientes principios: cada uno debe actuar de manera que no perturbe la sociedad de los demás hombres y que en las relaciones con los demás hombres debe preservarse la igualdad de derechos.

Con respecto al hombre, toma parte de lo dicho por Grocio y por Hobbes. Decía que en el hombre hay una fuerte dosis de maldad y egoísmo natural, pero que a su vez sentía una fuerte inclinación a la unión con otros hombres, de la superación de esta contradicción, surge una sociedad pacífica y estable.

Plantea que para la existencia de la sociedad y del Estado se requieren dos pactos: el primero entre los individuos y el segundo entre los ciudadanos y el gobierno.

El derecho natural actúa como límite al poder del soberano. Encuentra en el derecho natural un derecho verdadero, no sólo una guía moral

³¹ BODENHEIMER, E., Teoría..., cit., pág. 158.

para los actos del soberano. El problema aquí se plantea por la inexistencia de un tribunal ante el cual reclamar por las violaciones del príncipe al derecho natural. Sólo en casos muy extremos Pufendorf reconoce el derecho de rebelión frente a las arbitrariedades del soberano.

LOCKE (1637-1704). Ya con este filósofo el liberalismo cobra una configuración concreta. Plantea que en el pacto los hombres no entregan la totalidad de los derechos, sino sólo algunos, y siempre mantiene la posibilidad de resistir al gobierno, en caso de violación de los derechos naturales. Estos derechos naturales constituían una suerte de defensa frente a los abusos del poder.

El hombre en su estado de naturaleza era esencialmente bueno. Y, el derecho natural prescribía al hombre que en atención a la igualdad y a la independencia recíproca nadie debía perjudicar a otro.

El objetivo final del Derecho lo encontraba en ampliar y preservar la libertad.

TOMASIUS (1665-1728) opinaba que el Derecho se refiere a la conducta exterior de los hombres, es decir, al aspecto físico externo de los actos. La coacción sólo es posible en los deberes jurídicos, no en los morales.

Así, comienza a perfilarse una neta distinción entre moral y Derecho que, posteriormente, perfeccionará Kant.

WOLFF (1679-1754). La perfección del ser humano es el más alto deber y la más importante aspiración humana. En este criterio, Wolff determina que la justicia se encuentra en el deber moral de la autoperfección del hombre.

Esta búsqueda no puede realizarse en un estado de absoluta libertad, a tal fin, los hombres deben estar gobernados por un soberano benévolo y paternalista, que otorgue la paz y la seguridad necesarias para que el hombre desarrolle el camino de su propia perfección.

MONTESQUIEU (1689-1755). Se le debe la doctrina de la separación de poderes y la creación del sistema de frenos y contrapesos recíprocos, basado en la mutua interdependencia de poderes.

En el libro *Del Espíritu de las Leyes* comienza diciendo: *"Las leyes en su más amplia significación son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. En este sentido, todos los seres tienen sus leyes: las tiene la divinidad, el mundo material, las inteligencias superiores al hombre, los animales y el hombre mismo"*³².

³² MONTESQUIEU, *Del Espíritu de las Leyes*, cit., pág. 31.

ROUSSEAU (1712-1778). Para él, el gobierno era un mandato, y en tal sentido podía ser revocado o modificado por el pueblo que conservaba los atributos de la soberanía.

*"La soberanía reside en el pueblo, el cual debe ejercerla directamente, y no por representantes. El pueblo forma la voluntad general, que no es necesariamente la voluntad de todos, ni siquiera es suficiente que lo sea de todos: la de todos puede, no obstante, no ser la voluntad general. La voluntad general es en el fondo la voluntad justa"*³³.

La libertad e igualdad que el hombre poseía en su estado de naturaleza, la conservaba aún después de realizarse el pacto social.

En la obra *El Contrato Social* Rousseau dice: *"El más fuerte no es nunca lo bastante fuerte para ser siempre el amo, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. De aquí, el derecho del más fuerte, derecho tomado irónicamente en apariencia, y realmente establecido en principio... Consideremos por un momento este supuesto derecho. Yo afirmo que de él no resulta otra cosa que un galimatías inexplicable. Pues desde el momento en que es la fuerza la que hace el derecho, el efecto cambia con la causa: toda fuerza que supera la primera, sucede a su derecho. Desde el momento en que se puede desobedecer impunemente, se puede legítimamente, y puesto que el más fuerte tiene siempre razón, sólo se trata de procurar ser el más fuerte. Ahora bien, ¿qué derecho es ese que prescribe cuando la fuerza cesa? Si hay que obedecer por fuerza, no hay necesidad de obedecer por deber, y si no se es forzado a obedecer, ya no se está obligado a hacerlo. Se ve, pues, que esta palabra derecho no añade nada a la fuerza; no significa aquí absolutamente nada... Conven-gamos, pues, en que la fuerza no hace el derecho, y que no estamos obligados a obedecer más que a los poderes legítimos. Así, mi primera cuestión sigue planteada... Esclavitud y derecho son siempre contradictorias; se excluyen mutuamente. Sea de un hombre a un hombre, sea de un hombre a un pueblo, el siguiente argumento será siempre insensato: yo hago contigo un convenio todo en perjuicio tuyo y todo en provecho mío, convenio que yo cumpliré mientras me plazca y que tú cumplirás mientras me plazca"*³⁴.

KANT (1724-1804) define al Derecho como: *"El conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de un individuo puede coexistir con el arbitrio de otro bajo una ley general de libertad"*³⁵.

³³ GOLDSCHMIDT, op. cit., pág. 480.

³⁴ ROUSSEAU, *El Contrato Social*, págs. 159 a 161.

³⁵ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 184.

La función del Estado para Kant es la de garantizar el Derecho. Aquél no debe intervenir ni interferir en las actividades de los particulares. Su objetivo culmina en garantizarle a los individuos el goce pleno de sus derechos.

En el concepto del pacto social encuentra una idea, no un hecho, ni siquiera una hipótesis histórica. La idea de libertad, al igual que Rousseau, la consideraba innata y natural al hombre. Nos plantea que el hombre debe ser tratado como un fin en sí mismo y que la dignidad humana es contraria a cualquier tipo de explotación del hombre.

Por último, para Kant el Derecho: *"Se ocupa sólo de los actos externos, no de los motivos que conducen a ellos. El Derecho requiere meramente una conformidad externa con las normas establecidas de la vida social; tal conformidad puede estar motivada exclusivamente por la amenaza de coacción que hay detrás del Derecho"*³⁶.

Para concluir con la opinión de diversos autores sobre el tema del Derecho y la justicia, citaremos a dos notables juristas de nuestro medio.

CARLOS COSSIO elaboró la llamada teoría egológica o normativismo estimativo, en base a la fenomenología y al existencialismo. Nos plantea que el Derecho es conducta en interferencia intersubjetiva.

Con respecto a la justicia, Cossio opina que no es el único valor jurídico, junto a ella encuentra: el orden, la seguridad, la paz, el poder, la cooperación y la solidaridad. Sin embargo, el plexo valorativo tendría una estructura radiada en cuyo centro se encuentra la justicia.

"La justicia es el valor central y, por lo tanto, el de más alto rango, correspondiéndole la función de establecer la armonía entre todos los demás valores jurídicos; en efecto, para que haya auténtica justicia en la convivencia social, es necesario que se den con signo positivo todos los demás valores, a los que la justicia, coronando tal estado de cosas, dará su matiz esencial y supremo... Según el filósofo argentino, la verdadera justicia consiste en la creación de igualaciones de libertad como puntos de partida sucesivamente renovados... Aplicando ya su definición como criterio de justicia pura, agrega Cossio: 'Con nuestra definición, podemos decir que, en la justicia racional, lo suyo de la fórmula clásica deja de ser una enunciación vacía. Lo suyo que corresponde a cada hombre por ser hombre, es lo que a cada cual falta para estar en igualdad de condiciones con el alter ego con quien interfiere. Estamos pues en las antípodas de Aristóteles con su justicia distributiva; éste decía que había que dar bienes y honores en proporción a los méritos; a mayor mérito, mayor

³⁶ BODENHEIMER, E., *Teoría...*, cit., pág. 187.

*retribución y viceversa. Para nosotros el ideal dice lo contrario: la verdadera justicia consiste en dar más a los que están más abajo, para igualar puntos de partida en el presente vital"*³⁷.

Queremos dejar aclarado una discrepancia con el párrafo transcripto. Coincidimos en el concepto planteado, pero no en el sentido con que se analiza el criterio aristotélico. Entendemos que la justicia distributiva, tal como lo explicita Aristóteles, nos encomienda dar a cada uno en proporción a su mérito, y es aquí donde, precisamente, entendemos que el que más necesita, más debe recibir, el que se encuentra en inferioridad de condiciones, más protegido debe estar. El mérito que la justicia distributiva debe considerar, no sólo es el esfuerzo, su propia capacidad, su valor, su entrega, etcétera, sino también de otra índole como, por ejemplo, los citados, su necesidad y su inferioridad.

WERNER GOLDSCHMIDT nos plantea la teoría triárista del mundo jurídico, donde las jurídicas sociológica, normológica y dikelógica constituyen el meollo del mundo jurídico. En el tema que nos interesa (jurística dikelógica) dice: *"La definición clásica de la justicia, elaborada por los estoicos y formulada por Cicerón y Ulpiano, concibe la justicia como virtud. Así afirma el primero, que la justicia es 'el hábito del espíritu mantenido por la utilidad común que atribuye a cada uno lo suyo', y el segundo sostiene que se trata de la 'constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo'. Ya Aristóteles había considerado a la justicia como el hábito operativo de lo justo. Considerando la justicia, en el punto de partida, como virtud, lo justo es producido por el acto de justicia y es, por consiguiente, siempre un justo particular. El camino a la comprensión de la función pantónoma de la justicia queda así bloqueado... Desde este ángulo de vista la justicia constituye la valoración del reparto objetivo de todos los bienes y males entre todas y cada una de las personas. La virtud individual de la justicia no es sino un medio a fin de obtener este reparto... De la función pantónoma de la justicia se desprende, pues, que en rigor no existe sino la justicia divina. La justicia humana es siempre imperfecta en su realidad, y sólo una idea regulativa como ideal. La justicia de cualquiera de nuestras resoluciones se vicia por el desenvolvimiento incesante del mundo, por el contagio de cualquier entuerto en el rincón más apartado de la Tierra, por el progressus ad infinitum y, por último, por el regressus ad infinitum. Todo acto de justicia humana contiene necesariamente estos cuatro granitos de injusticia. Nuestra incapacidad teórica de prever el futuro, nuestra incapacidad práctica de deshacer todos los en-*

³⁷ TORRE, A., *Introducción...*, cit., pág. 243.

tuerτος y nuestra incapacidad teórico-práctica de relacionar todos los acontecimientos concomitantes provocados y causales, obstan a que se dé cima a un solo acto de justicia completa... Pero esta necesaria imperfección inherente a cada acto de justicia y que resulta del empleo del método de fraccionamiento con el cual descartamos lo porvenir, hacemos enmudecer las injusticias que nos rodean, podamos las ramas y nbs contentamos con desarraigar algunas de las raíces más visibles, no debe ser obstáculo para que el hombre realice actos de justicia, so pena de incurrir en la injusticia absoluta que consiste en la omisión de cometer injusticias relativas... El fraccionamiento produce eo ipso seguridad jurídica: cuanto más se fraccione el ejercicio de la justicia, tanto más seguro resulta. La seguridad jurídica no es, por ende, un valor especial sino que es el resultado del fraccionamiento, su subproducto, siendo el fraccionamiento una cualidad esencial de la justicia terrenal... El principio supremo de justicia consiste en asegurar a cada cual una esfera de libertad dentro de la cual sea capaz de desarrollar su personalidad, de convertirse de individuo en persona o, como a veces se suele decir, de personalizarse" ³⁸

Con esto, concluimos esta breve referencia histórica, sobre los distintos conceptos que el hombre fue desarrollando con respecto al Derecho y a la justicia. Ahora, vamos a determinar y analizar aquellas cuestiones que excluyen de nuestro accionar concreto al valor justicia.

En principio, vemos que la justicia se encuentra en contradicción absoluta con la arbitrariedad. Ésta indica un tratamiento caprichoso, sin regla alguna que permita prever la conducta a seguir. La decisión arbitraria se toma sin sujeción alguna, sin motivo objetivo. Por el contrario, la justicia determina un tratamiento ajustado a reglas generales de conducta, lo que en última instancia provoca que el trato justo sea a su vez un tratamiento constante, consecuente y previsible. La conducta arbitraria podemos asimilarla a la conducta caprichosa, que da o quita sin observar mérito alguno, atada al inconstante humor del que decide.

La justicia también excluye de su accionar a la venganza, ésta persigue aniquilar al enemigo, el odio anida en el ánimo de las personas y sólo se busca la destrucción del otro; por el contrario, la justicia pretende compensar el daño efectivamente sufrido, en su exacta medida. El que resuelve un conflicto con justicia, no pretende la venganza del ofendido, sólo busca volver las cosas —en la medida de lo posible— al estado anterior al evento dañoso. En el ánimo del que juzga con justicia no existe el odio, ni

³⁸ GOLDSCHMIDT, *op. cit.*, págs. 431-435.

el ánimo de destrucción del otro, sino la prudencia y la medida necesaria, que permitan otorgar a cada quien lo que de suyo le corresponde.

Por último, la justicia excluye al amor. El amor da, otorga, sin calcular ni medir, por el contrario, la justicia separa y aísla, pretende dar a cada cual lo que le corresponde, reafirmando la personalidad de cada uno. El amor implica necesariamente, entrega absoluta y sin reservas, todo lo funde y confunde. La justicia da de acuerdo al mérito y a la medida establecida objetivamente.

V. REALIZACIÓN DEL VALOR JUSTICIA

Cuando hablamos de las teorías relativistas, hemos dicho que poseen penetraciones esenciales en el ser del Derecho, pero su error consiste en absolutizar verdades parciales. Pretendemos no cometer el mismo error, por ello afirmamos que el valor justicia orienta la conformación del orden jurídico, su aplicación y nuestra propia conducta en relación social, además de orientar la evolución del conjunto de la comunidad hacia formas de convivencia más perfectas, es decir, más justas. En consecuencia, el Derecho es tal en la misma y exacta medida en que a su vez se encuentre orientado por la justicia. Pero la justicia no actúa sola en la conformación del orden jurídico, se encuentra con un material previo, con un orden ya establecido. Un orden del poder y de la propiedad que se resiste a cualquier transformación que se intente realizar. El poder, por definición, se encuentra en contradicción con cualquier tipo de limitación que se intente, su objetivo es la expansión permanente. Todo esto, vivo en el seno social, genera el material sobre el cual va a actuar el orden jurídico; entonces, la justicia no es la única fuerza que intenta orientar las conductas humanas mediante el Derecho, convive con otras fuerzas, que a su vez reclaman su participación en la conformación del orden del Derecho.

Hemos dicho que el valor justicia no existe en estado de universalidad en la realidad, en ella existen los actos singulares, concretos, a los que le atribuimos ser justos en virtud de su adecuación a la idea universal de justicia. Es esta idea la que mueve a los hombres a perseguir de manera ineludible la adecuación de las infinitas interrelaciones sociales a la concepción de ella. Pero nunca lo logra definitivamente. La evolución implica que siempre estemos en el estadio anterior, lo que a su vez motoriza la persecución del destino histórico del hombre (*vid.* Evolución). Imaginemos una sociedad en la que la justicia gobierna absolutamente, ya no cabría hablar de evolución. La perfección como destino humano sería un hecho palpable. Y todo lo que hemos dicho al intentar definir al hombre caería de manera irreversible. Por eso es que siempre nos encontramos un

paso atrás del ideal de justicia posible a nuestra sociedad concreta, lo que nos lleva a modificar las estructuras sociales, económicas, políticas y jurídicas, para adecuarlas a este nuevo paso que la humanidad da en la búsqueda de su perfección.

Además, en muchas oportunidades el Derecho claudica frente al orden del poder, a los intereses vivos que se entretajan en el seno social. Sucede que la evolución no se produce en línea recta, sino que la podemos graficar como una línea quebrada, cuyos puntos de inflexión son los excesos, por un lado, y los defectos, por el otro, en cuyo equilibrio histórico podemos observar una línea recta, dirigida a captar cada vez con mayor claridad y plenitud el valor justicia para, entonces, interponerlo en nuestra realidad.

"La justicia del Derecho se mueve siempre en el marco de un determinado orden del poder y de la propiedad, orden aceptado tal cual y cuya transformación en el sentido de la justicia tropieza siempre con tenaz resistencia. Aquí se abre el profundo abismo entre justicia del Derecho y justicia social, y éste es precisamente el frente en que siempre ha estallado la lucha entre el Derecho y la idea del Derecho, contra el Derecho en nombre de la idea del Derecho" ³⁹.

En nuestra realidad, la justicia no puede imponerse, no puede realizarse por sí misma, con la fatalidad y la necesidad con que ocurren los fenómenos de la naturaleza, gobernados por la causalidad. La justicia se realizará en nuestra realidad, en la misma medida en que haya hombres dispuestos a luchar por ella.

La justicia jurídica a realizar en una situación concreta es la justicia posible, de acuerdo a las convicciones jurídicas de la sociedad de que se trate. Convicciones éstas que se irán modificando, imperceptible, pero necesariamente, a tono con la evolución propia del hombre, lo que le permitirá en el decurso conocer con mayor plenitud el valor justicia, y a partir de ese único y exclusivo mecanismo, interponerlo en su realidad.

"La justicia jurídica es necesariamente una justicia fragmentaria. Nunca significa la última palabra, sino que es siempre una palabra provisoria. De toda sentencia judicial puede decirse en el fondo lo que se dice del juez de la fábula de Natán el sabio:

*"Por eso os cito ante este tribunal
para dentro de mil y de mil años:
Habrá entonces aquí un juez más sabio
que yo, y él hablará: Marchaos"* ⁴⁰.

³⁹ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 128.

⁴⁰ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 129.

En última instancia la justicia es una tarea a la que todos los hombres se encuentran convocados, con el objetivo de edificar la más excelsa construcción humana. Nuestro destino humano es precisamente esta tarea, realizada día a día y nunca jamás concluida.

VI. LA JUSTICIA EN SITUACIÓN DE COORDINACIÓN, SUBORDINACIÓN Y SOCIEDAD

En este punto seguimos lo expuesto por H. Coing, que distingue tres tipos de situaciones, a saber: de coordinación, de subordinación y de sociedad.

Antes de comenzar el análisis de cada una de ellas haremos algunas salvedades. Toda clasificación obedece a una mejor claridad expositiva, por lo tanto, no significa que en realidad se den con la misma pureza con que se las expone, sino que en la práctica las distintas situaciones se entremezclan y confunden y además existe entre ellas una vasta zona gris.

Hechas estas salvedades, vamos a describir cada una de las peculiaridades que corresponden a cada situación:

a) *Situación de coordinación*. En ésta los hombres resultan extraños entre sí, no existe superioridad alguna, sino que son libres, iguales e independientes. Es la situación prototípica del derecho privado y equivale a la relación de reconocimiento. El ejemplo clásico de esta situación es el contrato, donde los hombres que se encuentran entre sí libres, iguales e independientes, se unen para satisfacer necesidades, que si bien no son comunes sólo pueden satisfacerse mediante la participación del otro (v.gr., compraventa: uno vende, el otro compra).

b) *Situación de subordinación*. Es la situación que equivale a la relación de poder, aquí las personas se encuentran en clara desigualdad, es una situación de dominio de una persona sobre otra, existe una relación de superioridad por un lado y de sumisión por el otro. El ejemplo típico de esta situación la encontramos en la relación entre el Estado y los particulares.

c) *Situación de sociedad*. En esta situación los hombres se encuentran unidos y soportan comunitariamente las dichas y desdichas de la vida en común. Reparten entre ellos las cargas y los beneficios de esa comunidad. El ejemplo típico corresponde a las comunidades políticas (municipal, provincial, nacional).

VII. CLASES DE JUSTICIA

A cada una de las situaciones descriptas le corresponde un tipo particular de justicia, con características y peculiaridades que le son propias.

No significa esto que existan distintas clases de justicia. La justicia es una sola. El valor justicia en estado de universalidad, imperecedero y eterno, no admite divisiones ni clasificaciones, pero ésta se realiza en los actos singulares y concretos que son justos, y es allí, en la infinita gama de posibilidades distintas que ofrece la realidad, cambiante, perecedera, perfectible, donde la justicia toma las distintas características, en que un acto justo puede concretarse.

Ya Aristóteles nos habla de distintas clases de justicia (*vid.*, Evolución histórica del valor justicia, y libro V de la *Ética a Nicómaco*).

a) Situación de coordinación. Justicia conmutativa

A la situación de coordinación le corresponde un tipo particular de justicia, la que se denomina conmutativa (*iustitia conmutativa*). Ella establece, en primer lugar, el respeto recíproco de los derechos existentes, lo que significa que nadie puede lesionar impunemente los derechos subjetivos presentes en el otro, si pese a esta exigencia (de la que surgen prohibiciones concretas, v.gr., no matarás, no robarás) se violan los derechos del otro, la justicia conmutativa exige la reparación de la lesión causada en exacta proporción al daño efectivamente sufrido.

Hemos dicho que el ejemplo típico de esta situación es el contrato, para éste rigen determinados principios, que surgen del contenido propio de la justicia conmutativa. En la celebración de un contrato rige primordialmente el principio de la lealtad y la confianza (*pacta sunt servanda*). El artículo 1198 del Código Civil en su primer párrafo dice: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosíblemente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión...". De aquí surge que se castiga el dolo, el engaño, el comportamiento arbitrario y contradictorio. Asimismo, se exige la igualdad, la proporcionalidad y la equivalencia de las contraprestaciones. De aquí surgen prohibiciones concretas, por ejemplo, el enriquecimiento indebido, el abuso del derecho, etcétera. Sobre este último punto el artículo 1071 del Código Civil dice: "...La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contrarie los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres".

Por último, el orden jurídico basándose en los principios de la justicia conmutativa protege a cada una de las partes de la relación jurídica frente a la posible violación de la igualdad, proporcionalidad y equivalencia, mediante los institutos de la capacidad, de la nulidad, de la lesión enorme y de la imprevisión.

"Los principios de la justicia conmutativa han conseguido especial validez en el ámbito del derecho privado. Ellos constituyen el contenido propio de la equidad jurídico-privada. En el ámbito del derecho privado existe por antonomasia la situación de coordinación. Pero aquellos principios valen además en cualquier situación en la que se establezca la coordinación. Tal, por ejemplo, el caso del derecho internacional, en la medida en que se trata de relaciones entre Estados sobre pie de igualdad, y también en el derecho estatal interno mismo, siempre que la Constitución coloque en situación de coordinación determinados titulares del poder, como parlamento y corona, o distintos grupos políticos"⁴¹.

b) Situación de subordinación. Justicia protectiva

A la situación de subordinación le corresponde un tipo particular de justicia, la que ha sido denominada justicia protectiva.

En el Capítulo III al analizar el orden del Derecho y el orden del poder, hemos dicho que el poder y el Derecho se encuentran en una situación irreductible, sin embargo, el poder es accesible para el Derecho en la medida en que aquél se encuentre limitado. De esto se deduce que el primer principio que establece la justicia protectiva es aquel que determina que todo poder debe ser limitado, ya que de lo contrario se entraría necesariamente en colisión con el Derecho.

El poder es una creación humana, cuya existencia resulta indiscutible, el Derecho, a su vez, nos exige adecuarlo a los principios de justicia. Frente a esto, no basta con plantearnos la limitación del poder, sino que corresponde conformarlo de acuerdo a la naturaleza misma de las cosas y a la finalidad social de cada institución. Es decir, una vez limitado el poder, la comunidad al otorgar una posición de poder, debe controlar que la concentración de poder dado esté en relación directa e inmediata con la naturaleza de las cosas y la finalidad social perseguida; para ejemplificar vemos que no es la misma concentración de poder que posee un profesor que un agente de policía, ni un inspector de tránsito que un juez. En definitiva, el poder dado debe adecuarse a las exigencias que surgen de las cosas mismas y de la finalidad social buscada.

El poder en su ejercicio se encuentra sujeto y atado a normas generales de conducta, por lo que se excluye el trato arbitrario y discriminatorio, es decir, el poder debe ejercerse mediante el trato igualitario, sin ningún tipo de discriminaciones para todos los que se encuentran sujetos a él.

⁴¹ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 193.

Además, tanto el que ejerce, como el que se encuentra sujeto a un poder establecido, están sometidos a las mismas normas generales de conducta y si existe algún tipo de exigencia superior, siempre lo es para el titular del poder.

Por último, la justicia protectora determina que todo poder debe ser supervisado, debe existir un control posterior del acto del poder y, obviamente, ese control lo debe ejercer un tercero ajeno al titular del poder (sistema de frenos y contrapesos).

*"Los principios de la iustitia protectora valen en cualquier caso en que se presenten en el ámbito del Derecho relaciones de poder y queden sometidas a aquel ámbito. Su formulación más importante es el estado de derecho del liberalismo; sus precedentes son la democracia atica y la república romana, así como, en el derecho medieval, el derecho feudal y los privilegios de las ciudades. Pero también en el ámbito del derecho privado se presentan relaciones de poder, y encuentran, por lo tanto, aplicación aquellos principios: tal es, por ejemplo, el caso de la relación monopolista con quienes contratan con él, o las relaciones entre la asociación profesional y sus miembros. En el derecho internacional los principios de la iustitia protectora cobran relevancia cuando un estado o una minoría nacional tienen que vivir en dependencia de otra configuración estatal"*⁴²

c) Situación de sociedad. Justicia distributiva

A la situación de sociedad le corresponde un tipo particular de justicia, la que se ha llamado justicia distributiva.

*"La iustitia distributiva contiene principios acerca de la distribución de bienes y cargas. Se orienta a la situación de un grupo de hombres que persiguen fines comunes y que, por ello, desean repartirse entre todos las cargas necesarias así como los bienes conseguidos"*⁴³

Estas reglas de distribución de las cargas como de los bienes que se logran a partir de la actividad en común, excluyen a aquellas comunidades a las que hemos denominado auténticas comunidades personales (v.gr., familia, vid. Cap. II) ya que en ella las dichas y desdichas se soportan en común sin considerar los aportes ni los retiros de cada integrante. Al hablar de la situación de comunidad o sociedad, nos referimos a la llamada comunidad abstracta, donde los individuos no funden la totalidad de inte-

⁴² COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 196.

⁴³ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 197.

reses y deseos, como ocurre en la familia. Los integrantes de una Nación, de una provincia, de un municipio, de una Iglesia, de un club, de un colegio profesional, de un gremio, de una sociedad mercantil, etcétera, indudablemente tienen intereses comunes, pero a su vez son entre sí extraños, lo que determina la necesidad de regular el reparto entre todos de las cargas y los beneficios.

El principio esencial que nos plantea la justicia distributiva es la igualdad, sin privilegios ni excepciones.

Los problemas que acarrea el concepto de igualdad lo hemos planteado en el Capítulo II, ahora sólo precisaremos el sentido con que utilizamos el término igualdad. No nos referimos a una igualdad matemática, absoluta, sino que la justicia distributiva nos exige proporcionar los beneficios con las cargas. En algunos aspectos sociales esta cuestión se observa claramente (v.gr., impuestos directos), en otros la complejidad es mayor (v.gr., el salario de un cantante, un investigador y un albañil ¿cuáles son las escalas precisas para poder medir el aporte de cada uno, para que a su vez se conceda un beneficio proporcionado?).

También genera innumerables conflictos la redistribución de las riquezas generadas por una sociedad (v.gr., subsidios a determinados sectores; el mantenimiento del sistema de salud pública, o el sistema de educación pública).

Para todas estas cosas la justicia distributiva no tiene una respuesta precisa; en primer lugar, porque el reparto de bienes y cargas en las sociedades políticas se encuentra íntimamente unido a la eficacia y eficiencia de sus órganos y, en segundo lugar, porque vemos que la justicia distributiva o justicia social se encuentra en una etapa de redefinición. Obsérvese la enorme cantidad de propuestas generadas en estos últimos años sobre temas económicos, sociales, políticos, jurídicos, etcétera, que se refieren directa o indirectamente a la justicia distributiva. Lo que implica una enorme potencialidad intelectual aplicada a ese fin.

Finalmente, para determinar con precisión el contenido de la justicia distributiva en nuestro estadio evolutivo la planteamos como una escala de igualdad proporcionada a las cargas y a los beneficios.

Implica que cada uno de los integrantes de una sociedad —política, en nuestro ejemplo— debe ser tratado de acuerdo a su mérito ante el reparto de cargas y beneficios. Quien más necesita, más debe recibir. Quien más tiene, más debe aportar. Todo ello con criterios objetivos de igualdad proporcionada.

De cualquier manera, no podemos dejar de apuntar en este tema, que al tratarse de una cuestión de actualidad permanente, donde se generan grandes conflictos y se entremezclan profundos intereses, extraerse de esa

lucha e intentar definir objetivamente los principios de la justicia social resulta poco menos que una tarea imposible. Es en esta cuestión donde con mayor claridad podemos observar —por todo lo apuntado— el quiebre entre el Derecho y la idea del Derecho, entre el orden establecido y la lucha permanente por adecuarlo a un mayor criterio de justicia. Es, sin lugar a dudas, donde la evolución constante del hombre, en su búsqueda de interpolar lo justo en su realidad, se observa con mayor nitidez.

CAPÍTULO V CONCIENCIA JURÍDICA

I. EL SER

El problema del ser es uno de los temas centrales que aborda la filosofía. Los requerimientos de este trabajo nos impiden penetrar en la inmensa construcción ontológica que ha desarrollado el pensamiento humano, sin perjuicio de ello, nos detendremos someramente en el problema del ser de los valores.

Las ciencias en general delimitan perfectamente una porción del ser al que hacen objeto de su estudio, pero no se preocupan del ser en general. Para ejemplificar, vemos que las matemáticas estudian la magnitud, la física el movimiento. La filosofía, en cambio, estudia el ser, no ser una u otra cosa, sino el ser, que es lo que es.

“Efectivamente, esa ciencia, concebida como la más elevada, aparece ante todo como la más general: tiene por objeto el ser, ya que el ser es lo que hay de más general. Lo que es común a todas las cosas. Las ciencias particulares apartan y circunscriben un aspecto o una parte bien definida del ser para hacer de él el objeto de su estudio; la filosofía, por el contrario, estudia el ser en cuanto tal y sus atributos esenciales... Esas propiedades pertenecen al ser por sí mismo y en cuanto tal, como pertenece al número el ser par o impar, conmensurable, o igual, demasiado o deficiente... Lo mismo ocurre con lo que concierne al género que constituye el objeto de una ciencia particular, el objeto que en general se propone ella estudiar; se lo delimita sin que se defina su esencia, y sin que se ponga siquiera en cuestión si realmente es, sin que se establezca su existencia. El matemático supone que hay magnitudes; el físico admite, fiándose de los sentidos, que hay movimiento; postulan ambos, el uno el ser como cantidad y el otro el ser como movido; únicamente a la filo-

sófa le corresponde establecer que la cantidad y el movimiento son atributos del ser, mostrar a la vez lo qué son y el qué son”¹.

Para Platón, el verdadero ser de las cosas se encuentra en las ideas. La idea es el ser propio y verdadero de las cosas. Las cosas y objetos del mundo terreno son una representación más o menos fiel de las esencias. No sólo se refiere a lo bueno en sí, a lo justo en sí y demás ideas éticas, sino que comienza a delinear conceptos ontológicos, como lo igual, lo diverso, etcétera.

En el *Fedón*, Platón dice: “Luego, antes de que nosotros empezáramos a ver, a oír y a tener las demás percepciones, fue preciso que hubiéramos adquirido de algún modo el conocimiento de lo que es igual en sí, si es que a esto íbamos a referir las igualdades que nos muestran las perfecciones de las cosas, y pensar, al referirlas, que todas ellas se esfuerzan por ser de la misma índole que aquello, pero son sin embargo inferiores... Pues bien, si lo adquirimos antes de nacer y nacimos con él, ¿no sabíamos ya antes de nacer e inmediatamente después de nacer, no sólo lo que es igual en sí, sino también lo mayor, lo menor y todas las demás cosas de este tipo? Pues nuestro razonamiento versa más sobre lo igual en sí, que sobre lo bello en sí, lo bueno en sí, lo justo, lo santo, o sobre todas aquellas cosas que, como digo, sellamos con el rótulo de lo que es en sí, tanto en las preguntas que planteamos como en las respuestas que damos. De suerte que es necesario que hayamos adquirido antes de nacer los conocimientos de todas estas cosas... ¿Y es que la cuestión, Simmias, se nos presenta así? —continuó Sócrates—. Si, como repetimos una y otra vez, existe lo bello, lo bueno y todo lo que es una realidad semejante, y a ella referimos todo lo que procede de las sensaciones, porque encontramos en ella algo que existía anteriormente y nos pertenecía, es necesario que, de la misma manera que dichas realidades existen, exista también nuestra alma, incluso antes de que nosotros naciéramos. Pero si éstas no existen, ¿No se habría dicho en vano este pensamiento? ¿No se presenta así la cuestión? ¿No hay una igual necesidad de que existan estas realidades y nuestras almas, antes incluso, de que nosotros naciéramos y de que, si no existen aquéllas, tampoco existen éstas?

—Es extraordinaria, Sócrates, la impresión que tengo —dijo Simmias— de que hay la misma necesidad. Y el razonamiento arriba a buen puerto, a saber, que nuestras almas existen antes de nacer nosotros del mismo modo que la realidad de la que acabas de hablar. Pues nada tengo por tan evidente como el que lo bello, lo bueno, y todas las demás cosas de

esta índole de que hace un momento hablabas tiene existencia en grado sumo; y en mi opinión al menos, la demostración queda hecha de un modo satisfactorio...

—¿Y no decíamos también hace un momento que el alma, cuando usa del cuerpo para considerar algo, bien sea mediante la vista, el oído o algún otro sentido —pues es valerse del cuerpo como instrumento el considerar algo mediante un sentido— es arrastrada por el cuerpo a lo que nunca se presenta en el mismo sentido y se extravía, se embrolla y se marea como si estuviera ebria, por haber entrado en contacto con cosas de esta índole?

—En efecto.

—¿Y no agregábamos que, por el contrario, cuando reflexiona a solas consigo misma y le es posible, y siempre queda igual y en el mismo estado con relación a esas realidades, puesto que ha entrado en contacto con los objetos que, asimismo, son idénticos e inmutables? ¿Y que esta experiencia del alma se llama pensamiento?”².

De lo que hemos transcripto en este párrafo y en las anteriores citas que hemos realizado, con respecto al pensamiento de Platón, podemos deducir que busca una entidad en la cual fundar una verdadera ciencia que se mantenga al margen de los cambios constantes que la realidad cotidiana nos presenta, a eso llama esencias, ideas. Este razonamiento, en última instancia, nos dice que podemos —por ejemplo— dibujar un triángulo, pero éste nunca tendrá la perfección absoluta de la idea del triángulo. O, en otro caso, tenemos la idea del caballo, prescindiendo de su pelaje, de su alzada, etcétera. Estas ideas son realidades auténticas, primeras, de las que surgen como remedos las cosas y los objetos que se presentan en nuestra realidad cotidiana.

Esto lo explica con belleza sin par en el mito de la caverna. Imagina una caverna en la cual un grupo de hombres hayan nacido y se hayan criado. Éstos en virtud de hallarse encadenados se encuentran imposibilitados de mirar hacia atrás, sólo pueden ver el fondo de la caverna. Entre ellos y una fuente de luz (el fuego) pasan personas portando pancartas —que representan objetos reales— las que se reflejan en el fondo de la caverna (hacia el único lugar que pueden mirar estos singulares prisioneros). Lo que determina que estos hombres pensarían y argumentarían que esas formas que se reflejan en el fondo de la caverna son las únicas realidades posibles. En ese particular mundo lo único que existe son ellos y las sombras como realidades tangibles.

¹ MOREAU, *Aristóteles y su Escuela*, Eudeba, Buenos Aires, 1972, pág. 68.

² PLATÓN, *Fedón*, págs. 171. 172. 179.

Pero ocurre que uno de ellos puede escaparse de la caverna. Cuando sale al exterior, luego del necesario período de adaptación que el ojo requiere a la luz, será capaz de ver los objetos, ya no reflejados, sino en sí mismos.

Continúa el relato, que el evadido retorna a la caverna a explicar lo que ha visto, pero se encuentra con la incompreensión y descreimiento de sus antiguos compañeros.

Considera Platón, que los prisioneros continuarán pensando que la realidad son las sombras, y que la única existencia posible es esa y que la existencia de otro mundo es sólo el desvarío que la evasión provocó en aquél que se atrevió a buscar más allá de sus propios límites.

"Y ahora —proseguí— compara con el siguiente cuadro imaginario el estado de nuestra naturaleza según esté o no esclarecida por la educación. Representate a unos hombres encerrados en una especie de vivienda subterránea en forma de caverna, cuya entrada, abierta a la luz, se extiende en toda su longitud. Allí, desde su infancia, los hombres están encadenados por el cuello y por las piernas, de suerte que permanecen inmóviles y sólo pueden ver los objetos que tienen delante, pues las cadenas les impiden volver la cabeza. Detrás de ellos, a cierta distancia y a cierta altura, hay un fuego cuyo resplandor alumbrá, y entre ese fuego y los cautivos se extiende un camino escarpado, a lo largo del cual imagina que se alza una tapia semejante al biombo que los titiriteros levantan entre ellos y los espectadores y por encima del cual exhiben sus fantoches.

"—Imagino el cuadro —dijo—.

"—Figúrate, además, a lo largo de la tapia, a unos hombres que llevan objetos de toda clase y que se elevan por encima de ella, objetos que representan en piedra o madera, figuras de hombres y animales y de mil formas diferentes. Y como es natural, entre los que llevan, algunos conversan, otros pasan sin decir palabra.

"—¡Extraño cuadro y extraños cautivos! —exclamó—.

"—Semejantes a nosotros —repliqué—. Y, ante todo, ¿crees tú que en esa situación puedan ver, de sí mismos y de los que a su lado caminan, alguna otra cosa fuera de las sombras que se proyectan, al resplandor del fuego, sobre el fondo de la caverna expuesto a sus miradas?

"—No —contestó—, porque están obligados a tener inmóvil la cabeza durante toda su vida.

"—Y, en cuanto a los objetos que transportan a sus espaldas, ¿podrán ver otra cosa que no sea su sombra?

"—¿Qué más pueden ver?

"—Y si pudieran hablar entre sí, ¿no juzgas que considerarían objetos reales las sombras que vieran?

"—Necesariamente.

"—¿Y qué pensarían si en el fondo de la prisión hubiera un eco que repitiera las palabras de los que pasan? ¿Crearían oír otra cosa que la voz de la sombra que desfila ante sus ojos?

"—¡No por Zeus! —exclamó—.

"—Es indudable —proseguí— que no tendrán por verdadera otra cosa que no sea la sombra de esos objetos artificiales.

"—Es indudable —asintió—.

"—Considera ahora —proseguí— lo que naturalmente sucedería si se los librara de sus cadenas a la vez que se los curara de su ignorancia. Si a uno de esos cautivos se lo libra de sus cadenas y se lo obliga a ponerse súbitamente de pie, a volver la cabeza, a caminar, a mirar la luz, todos estos movimientos le causarán dolor y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuya sombra veía momentos antes.

"—¿Qué habría de responder, entonces, si se le dijera que momentos antes sólo veía vanas sombras y que ahora, más cerca de la realidad y vuelta la mirada hacia objetos reales, goza de una visión verdadera? ¿Supongamos, también, que al señalarle cada uno de los objetos que pasan, se le obligara, a fuerza de preguntas, a responder qué eran; ¿no pensarías que quedaría perplejo y que aquello que antes veía habría de parecerle más verdadero que lo que ahora se le muestra?

"—Mucho más verdadero —dijo—.

"—Si se le obligara a mirar la luz misma del fuego, ¿no herirá ésta los ojos? ¿No habrá de desviarlos para volverlos a las sombras, que puede contemplar sin dolor? ¿No las juzgará más nítidas que los objetos que se le muestran?

"—Así es —dijo—.

"—Y en caso de que lo arrancara por fuerza de la caverna —proseguí— haciéndolo subir por el áspero y escarpado sendero, y no se lo soltara hasta sacarlo de la luz del sol, ¿no crees que lanzará gritos de cólera? Y al llegar a la luz, ¿podrán sus ojos deslumbrados distinguir uno siquiera de los objetos que nosotros llamamos verdaderos?

"—Al principio, al menos, no podrá distinguirlos —contestó—.

"—Si no me engaño —proseguí— necesitará acostumbrarse para ver los objetos de la región superior, lo que más fácilmente distinguirá serán las sombras, luego las imágenes de los hombres y de los demás objetos que se reflejan en las aguas y, por último, los objetos mismos; después, elevando su mirada hacia la luz de los astros y de la luna, contemplará durante las noches las constelaciones y el firmamento más fácilmente que durante el día el Sol y el resplandor del Sol.

"—Sin duda.

"—Por último creo yo, podría fijar su vista en el Sol, y sería capaz de contemplarlo, no sólo en las aguas o en las otras superficies que lo reflejan, sino tal cual es, y allí donde verdaderamente se encuentra.

"—Necesariamente de lo cual, reflexionando sobre el Sol, llegará a la conclusión de que éste produce las estaciones y los años, lo gobierna todo en el mundo visible y que, de una manera u otra, es la causa de cuanto veía en la caverna con sus compañeros de cautiverio.

"—Es evidente —afirmó— que, después de sus experiencias, llegaría a esas conclusiones.

"—Si recordara entonces su antigua morada y el saber que allí se tiene, y pensara en sus compañeros de esclavitud, ¿no crees que se consideraría dichoso con el cambio y se compadecería de ellos?

"—Seguramente.

"—Y suponiendo que allí hubiese honores, alabanzas y recompensas establecidos entre sus moradores para premiar a quien discerniera con mayor agudeza las sombras errantes y recordara mejor cuáles pasaron primeras o últimas, o cuáles marchaban juntas y que por ello, fuese más capaz de predecir su aparición. ¿Piensas tú que nuestro hombre seguiría deseoso de aquellas distinciones y envidiaría a los colmados de honores y autoridad en la caverna? ¿O preferiría acaso, como dice Homero, 'trabajar la tierra al servicio de otro hombre sin patrimonio'. Y sufrirlo todo en el mundo antes de volver a juzgar las cosas como se juzgaban allí y vivir como allí se vivía?

"—Yo, al menos —dijo— creo que estaría dispuesto a sufrir cualquier situación antes de vivir de aquella manera.

"—Y ahora considera lo siguiente —proseguí— supongamos que ese hombre desciende de nuevo a la caverna y va a sentarse en su antiguo lugar. ¿No quedarán sus ojos como cegados por las tinieblas, al llegar bruscamente desde la luz del sol?

"—Desde luego —dijo—.

"—Y cuando su vista se hallaba todavía nublada, antes de que sus ojos se adapten a la oscuridad —lo cual no exige poco tiempo— tuviera que competir con los que continuaron encadenados, dando su opinión sobre aquellas sombras. ¿No se expondrá a que se rían de él? ¿No le dirán que por haber subido a las alturas ha perdido la vista y que ni siquiera vale la pena intentar el ascenso? Y si alguien ensayara liberarlos y conducirlos a la región de la luz, y ellos pudieran apoderarse de él y matarlo, ¿es que no lo matarían?

"—Con toda seguridad —dijo—.

"—Pues bien —continué—, ahí tienes, amigo Glaucón la imagen precisa a que debemos ajustar por comparación, lo que hemos dicho an-

tes: el antro subterráneo es este mundo visible; el resplandor del fuego que lo ilumina es la luz del Sol; si en el cautivo que asciende a la región superior y la contempla te figuras el alma que se eleva al mundo intangible, no te engañarás sobre mi pensamiento, puesto que deseas conocerlo.

"—Dios sabrá si es verdadero, pero, en cuanto a mí, creo que las cosas son como acabo de exponer. En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con dificultad, pero que no podemos percibir sin llegar a la conclusión de que es la causa universal de cuanto existe de recto y de bueno; a que en el mundo visible crea la luz y el astro que la dispensa; que en el mundo inteligible engendra y procura la verdad y la inteligencia y que, por lo tanto, debemos tener los ojos fijos en ella para conducirnos sabiamente, tanto en la vida privada como en la pública. Comparto tu opinión —replicó— hasta donde puedo entenderte.

"—Entonces —proseguí— admite asimismo y no te extrañes que aquellos que han llegado a esas alturas no quieran ocuparse de los asuntos humanos y que sus almas aspiren sin cesar a mantenerse en la región superior y vivir en lo sublime. Nada más natural, creo yo, si también acerca de este punto debemos atenernos a la imagen trazada.

"—Es natural, ciertamente —dijo—.

"—¿Y qué? —pregunté yo— ¿piensa que es de extrañar que un hombre que pasa de las contemplaciones divinas a los miserables intereses humanos parezca torpe y enteramente ridículo cuando, teniendo aún la vista nublada y antes de haberse acostumbrado lo suficiente a las tinieblas que lo rodean, se vea obligado a disputar ante los tribunales o en cualquier otro sitio acerca de las sombras de la justicia o de las imágenes que esas sombras proyectan y a combatir las interpretaciones que de ella hacen los que jamás han visto la justicia en sí?

"—Es imposible extrañarse de eso —contestó—.

"—Antes bien —proseguí— una persona sensata ha de recordar que la vista puede turbarse de dos maneras y por dos causas opuestas: cuando se pasa de la luz a la oscuridad, o de la oscuridad a la luz. Y si reflexionamos que lo propio sucede con el alma, cuando vea un alma turbada y en dificultad para discernir los objetos, en vez de burlarse insensatamente, estudiará si esa dificultad proviene de que, como sale de una visión más luminosa se encuentra ofuscada por las tinieblas; o de que, al pasar de la ignorancia a la luz, queda deslumbrada por su vivo resplandor. En el primer caso, la felicitará por su actitud ante la vida; en el segundo se compadecerá de ella y, si quisiera reír a sus expensas, sus burlas serían menos ridículas que si fueran dirigidas al alma que desciende de la luz.

"—Hablas muy acertadamente —dijo—.

"—Si todo esto es cierto —proseguí— debemos considerar que la educación no es lo que ciertos hombres pretenden. Afirman, en efecto, que si falta ciencia en un alma ellos la proporcionan como si infundieran visión a unos ojos ciegos.

"—Por cierto que lo afirman —dijo—.

"—Pero lo que estamos diciendo —proseguí— nos hace ver que cada cual tiene en su alma la facultad de aprender y el instrumento destinado a ese uso y que, a semejanza del ojo que no podría volverse de las tinieblas a la luz sino en compañía de todo el cuerpo, del mismo modo este instrumento debe apartarse en compañía de toda el alma de las cosas perecederas, es decir, de lo que nace, hasta poder soportar la contemplación del ser y lo más luminoso del ser, que hemos llamado el bien. ¿No es así?

"—Así es.

"—La educación —dije— es el arte de dirigir este instrumento y encontrar para ello el método más fácil y eficaz. No se trata de infundirle la visión, porque ya la tiene; pero está desviado y no mira hacia donde debiera. Esto es lo que importa corregir.

"—Eso me parece —dijo—.

"—Ahora bien, podemos admitir que las demás facultades, llamadas facultades del alma, son análogas a las del cuerpo; si faltan al principio, después pueden adquirirse por el hábito y el ejercicio. Pero la facultad del conocimiento pertenece, sin duda, a algo más, pierde su fuerza y que, según la dirección que se le dé, viene a ser útil o inútil, ventajoso o perjudicial. ¿No has observado hasta dónde llevan su sagacidad esos individuos de quienes se dice que son malos, pero inteligentes, y con qué agudeza sus almas ruines distinguen aquello a lo que se aplican? Obligan a su visión, en modo alguno débil, a servir de instrumento a su malicia, de suerte que, cuanto más penetrante sea, tanto mayor será el daño que cometa.

"—Sin duda —dijo—.

"—No obstante —proseguí— si desde la infancia se operase el alma de tal modo conformada por la naturaleza y se extirpara de ella, por así decirlo, esas adherencias de plomo, destinadas a desarrollarse, que la arrastran a la gula y a otros placeres y apetitos semejantes y dirigen su visión hacia las cosas inferiores; si el alma, libre de ellas, hubiera sido encaminada hacia la verdad, esos hombres las percibirían con la misma sagacidad con la que perciben las cosas sobre las cuales fijan ahora su atención.

"—Es probable —afirmó—.

"—¿Y no es también probable —repliqué— o, mejor, necesaria consecuencia de cuanto hemos dicho acerca de que no son aptos para el go-

bierno de la ciudad los hombres que no han recibido educación y no tienen conocimiento alguno de la verdad. Ni tampoco aquéllos que se han pasado toda la vida en el estudio? Los primeros porque no tienen en la vida un determinado objetivo al que puedan dirigir todos sus actos, tanto públicos como privados; los segundos, porque no consentirán nunca que se eche sobre ellos semejante carga, creyéndose ya en vida en las islas de los bienaventurados.

"—Es verdad —contestó—.

"—Nos corresponde, pues, a nosotros, los fundadores de la ciudad —proseguí—, obligar a las mejores naturalezas a que alcancen ese conocimiento que acabamos de reconocer como el más sublime de todos, contemplen el bien y realicen esa ascensión de la que hemos hablado; pero una vez que se hayan elevado hasta él y lo hayan contemplado por bastante tiempo, guardémonos de permitirles lo que hoy se les permite.

"—¿Qué es ello?

"—Permanecer allí —contesté— negándose a bajar de nuevo al lado de los cautivos, para tomar parte en sus trabajos e incluso participar de sus honores, sean éstos de poca o mucha importancia.

"—En este caso —observó— ¿no seremos injustos con ellos y los condenaremos a una vida miserable, cuando podrían gozar de una condición mejor?

"—Una vez más te olvidas, mi querido amigo —contesté— que la ley no se propone la felicidad de una clase de ciudadanos, con exclusión de las otras, sino el bienestar de todos, uniéndolos por la persuasión y por la autoridad, y llevándolos a participar de las ventajas que cada cual puede aportar a la comunidad. Si la ley, pues, se consagra a formar tales ciudadanos, no será para dejar que cada uno de ellos se aplique a lo que quiere, sino para hacernos concurrir a la cohesión de la ciudad.

"—Es verdad —dijo—, lo había olvidado.

"—Por lo demás, Glaucón —proseguí— ten presente que tampoco podrá culpárselos de injustos para los filósofos que se formarán entre nosotros, y que podremos darles buenas razones para obligarlos a que se encarguen de la dirección y salvaguarda de sus conciudadanos. Les diremos, en efecto: 'En las demás ciudades, los hombres como vosotros se abstienen, sin razón, de participar en las cargas públicas, porque se han formado ellos mismos, a pesar de los gobiernos, y es justo que el que se ha formado a sí mismo y a nadie debe su crianza no pague a nadie los gastos que le ocasionó. Pero nosotros os hemos formado jefes y reyes, como en las colmenas, en el interés de vosotros mismos y de los demás ciudadanos, y al daros una educación más perfecta y más completa que la de los filósofos extranjeros, os hemos vuelto capaces de unir la filosofía a la políti-

ca. Por lo tanto, debéis descender por turno a la morada de vuestros ciudadanos y acostumbrar vuestros ojos a las tinieblas que allí reinan; una vez que os hayáis familiarizado con la oscuridad, veréis en ella mil veces mejor que sus moradores y reconoceréis la naturaleza de cada imagen y el objeto que representa, porque habréis contemplado lo bello, lo justo y lo bueno en sí. De tal modo, la organización de la ciudad será para vosotros y para nosotros una realidad y no un sueño, como ocurre en la mayoría de las demás ciudades cuyos jefes luchan entre sí por sombras vanas y se disputan encarnizadamente la autoridad como si fuese un gran bien. Precisamente, a mi juicio, la verdad es ésta: toda ciudad en que menos deseosos de gobernar estén aquellos que deberán hacerlo, será necesariamente la mejor y más pacíficamente gobernada, al paso que sucederá lo contrario a la que tenga gobernantes de contraria intención'.

"—Sin duda alguna —afirmó—.

"—¿No se rendirán nuestros discípulos a la fuerza de estos argumentos? ¿Crees tú que se negarán a participar, alternativamente, en la labor política de la ciudad para ir después a pasar juntos la mayor parte de su vida en el mundo de la luz pura?

"—No podrán negarse —contestó—, ya que prescribiremos cosas justas a hombres justos. Pero cada uno de ellos asumirá el gobierno como una carga indispensable, contrariamente a lo que hacen hoy los gobernantes de las ciudades.

"—Así es, amigo mío —proseguí—. Si descubres, para los destinados a mandar, una condición de vida mejor que la de gobernantes, podrás descubrir también una ciudad bien gobernada, pues sólo en ella mandarán los verdaderos ricos, no en oro, por cierto, sino en lo que debe ser rico el hombre feliz, es decir, en virtud y sabiduría. Pero esto es imposible si llegan a la función pública hombres indigentes y ávidos de riquezas personales; persuadidos de que habrán de adquirirlas cuando asuman el gobierno, porque entonces se disputarán la autoridad, y esa lucha doméstica e intestina acabará por perderlos junto con la ciudad misma.

"—Nada más cierto —dijo—.

"—Pues bien —continué—, ¿conoces tú otra condición de vida, excepción hecha de la del verdadero filósofo, que desdeñe los cargos públicos?

"—¡No, por Zeus! —respondió—.

"—Además, conviene que lleguen al gobierno los que no lo desean; de no ser así, la rivalidad suscitará querellas entre los pretendientes.

"—Sin duda.

"—Por consiguiente, ¿a quiénes impondrán la tarea de salvaguardar la ciudad sino a los mejores instruidos en el arte de organizarla y que

disfrutan además, de otros honores y llevan una vida preferible a la del político?

"—Sólo a ellos —respondió—" ³.

De la lectura de la extensa cita transcrita podemos deducir, que en la convicción de Platón, la verdad se encuentra en nosotros mismos, que conocer es recordar lo que cada uno de nosotros es portador y que se encuentra oculto entre la oscuridad y las sombras. Mediante el ejercicio intelectual, las sombras y la oscuridad se disipan hasta lograr contemplar cabalmente las esencias. Tal es el objetivo de la filosofía, buscar y encontrar la verdad.

Aristóteles nos enseña que existe una ciencia que no investiga regiones particulares del ser, como por ejemplo la matemática o la medicina, sino que estudia todo el ser en general. El ser en cuanto es. "Hay una ciencia que considera al ser en cuanto tal y todo lo que esencialmente le conviene" ⁴.

La metafísica es la ciencia del ser. Las demás ciencias se refieren al ser y presuponen de él los conceptos que le corresponden: la idea de oposición, identidad, todo, parte, especie, género, etcétera.

"Si se quiere dar una explicación como tal, se presenta inmediatamente de un modo natural el concepto de ousia, que quiere decir justamente ser, ente, concepto que había ya usado ampliamente la filosofía antes de Aristóteles, particularmente Platón.

"Aristóteles repara ante todo en que este concepto no es un concepto unívoco 'El ser se dice de muchas maneras' (Met. T. II; 1003 a 33). Ser tiene Sócrates en su individualidad; ser tiene también el hombre como tal en su esencia general; ser tiene una determinada propiedad que siempre se encuentra como accidente en una sustancia; ser tiene una unidad de valor ideal, pues decimos, por ejemplo, que dos y dos son cuatro, ser tiene el cuerpo, y ser, aunque distinto, tiene el alma; ser llamamos a lo real y también decimos ser a lo posible; asignamos el ser al pasado que ya fue y a lo por venir que aún no es" ⁵.

Luego Aristóteles, al definir el ser, uniendo los conceptos de ser y existir comienza a delinear una nítida diferencia con el maestro.

Dice Aristóteles en un pasaje del *Organon*: No es lo mismo ser esto que aquello que ser absolutamente. "Cuando pregunto si es o no es un

³ PLATÓN, *La República*, cit., págs. 381/390.

⁴ ARISTÓTELES, *Metafísica*, 1003 a 1021.

⁵ HIRSCHBERGER, *op. cit.*, pág. 170.

centauro o un dios, entiendo si es o no es en sentido absoluto, y no si es blanco o de otro color.

"Esta distinción es la del verbo *ser* cuando expresa la existencia a la realidad (verbo sustantivo) y del verbo *ser* cuando indica la atribución empleada como cópula del juicio, significando solamente una relación. Pero de esta distinción no infiere Aristóteles la separación metafísica entre la esencia y la existencia, es decir, la concepción de una verdad independiente de la realidad. Esta concepción propia del idealismo matemático resulta del platonismo y vuelve a encontrarse en el cartesianismo; considera que la esencia, las relaciones necesarias comprendidas en ella son verdades eternas, trascendentes a sus realizaciones empíricas, anteriores a los objetos que ellas determinan. Aristóteles no admite semejante criterio: la verdad, en su opinión, no puede ser anterior a las cosas; la verdad y la falsedad no residen tampoco en las cosas; se reducen a modalidades del pensamiento, y no se expresan más que en relaciones, en la unión y separación de términos que tienen su realidad fuera del pensamiento. Éste es verdadero si los términos que une o separa están también unidos o separados en la realidad; es falso en el caso contrario. Pero la verdad de las relaciones supone siempre la realidad de los términos comparados; las relaciones establecidas por el juicio, expresadas por el verbo *ser*, signo de atribución, no son nada por sí mismas, el *ser* así empleado, indica solamente un nexo que no se puede concebir sin los términos que conecta.

"No se podría proclamar con mayor claridad que la verdad se supe-dite a la realidad, que la esencia supone existencia. Hemos hecho notar ya que según Aristóteles no se puede decir de un sujeto lo que es, lograr una definición real de él, es decir, no meramente nominal, antes de saber si existe, aquí nos ratifica de nuevo que no se podría afirmar un atributo de su sujeto, afirmar una verdad, un lo que es, sin que el sujeto sea real. La distinción entre el *ser* absoluto, el *ser* relacional o atributivo, el *ser* sustantivo, no culmina, pues, a juicio de Aristóteles, en afirmar la autonomía de la verdad, en fundar el *ser* ideal de la esencia... El caballo, el hombre son universales que no existen fuera de los caballos o de los hombres singulares, tales como Alejandro o Bucéfalo"⁶.

Finalmente Aristóteles nos plantea una sustancia segunda, la esencia de la esencia. Determina a partir de ella que el *ser* concreto, singular, que se compone de materia y forma, corresponde a lo que es en sentido absoluto, esto es la sustancia inmaterial, las formas puras.

⁶ MOREAU, *op. cit.*, págs. 73 a 75.

"Esta actitud de Aristóteles frente a Platón es la que ha fijado el concepto de realidad durante siglos, hasta los comienzos del idealismo en la Edad Moderna y ha tenido la culpa de que cuando se habla de realidad se entienda, por lo común, exclusivamente objetos del mundo natural. Como si el alma no fuera cosa real y como si no constituyeran las relaciones lógicas y los valores, por ejemplo, algo real y 'aere perennius'. ¿Con qué derecho se contrae en el pensamiento moderno tantas veces la auténtica realidad al solo mundo sensible?... Pero ahora nos espera una sorpresa. Aristóteles no va a quedarse en la sustancia primera. Es ésta, para él, ciertamente la esencia, y lo permanente y el fundamento de un complejo de apariencias y manifestaciones cambiantes. Pero Aristóteles avanza un paso más y se pregunta qué es aquello que hace que la sustancia primera sea lo que es. Es decir, viene como a suponer una esencia de la esencia. Sócrates es, en cuanto sustancia, el núcleo central de todos los fenómenos a él vinculados. Pero ocurre preguntar de nuevo: ¿Qué es propiamente esta misma sustancia Sócrates? La respuesta es: Sócrates es hombre. De forma que viene ahora a entenderse lo que es Sócrates desde lo general, desde la esencia. Este universal específico, constituye el *ser* esencial. Es la sustancia segunda. Y Aristóteles nos asegura que esta sustancia segunda es en cuanto a la naturaleza, algo anterior y más conocido... El universal se declara más importante que el singular; pues ahora el individuo ha de ser entendido a partir del universal"⁷.

"La filosofía primera o ciencia del *ser* en cuanto tal, aparece así como una ontología general, fruto de una reflexión sobre la lógica, sobre las condiciones del lenguaje, y emparentada con la dialéctica platónica, tal como se la practica en el sofista. Así aparece, al menos, en los primeros libros de la metafísica; pero a partir del libro Z adopta una nueva orientación: en vez de un estudio del *ser* en general, pasa a ser un estudio del *ser* en su sentido primordial, es decir, de la ousia o sustancia. Después, en virtud de un análisis del *ser* concreto, singular, compuesto de materia y forma, descubre que finalmente lo que es, en sentido absoluto, es la sustancia inmaterial, la que es forma pura; de este modo, en el libro, la metafísica aristotélica se transforma en teología. El *ser* en cuanto tal no aparece entonces como el *ser* en general, sino como el *ser* por sí, el absoluto, el acto puro... Ahora bien, si es por falta de determinación porque está privada de forma, por lo que la materia, a pesar de su carga fundamental de sustrato, no puede considerarse ousia, ni es una sustancia en acto, ¿no habrá que reconocer que es en virtud de la forma como el *ser*

⁷ HIRSCHBERGER, *op. cit.*, pág. 174.

concreto, compuesto de materia y forma, merece que se lo considere ousia? La ousia en sentido primordial no sería en tal caso el ser singular, opuesto en el tratado de las categorías al género y a la especie, a los cuales conviene solamente la denominación de ousia segunda; sería por el contrario, la eidos o forma. Del análisis de la generación, por la que se producen los seres sensibles, vemos surgir lo que puede denominarse la aporía de la ousia: ¿es ésta el sujeto singular, la sustancia, o es la forma por la cual esto se hace lo que es, lo que tenía que ser, la quiddidad o la esencia? ¿Al realismo empírico, que ve la realidad en los objetos singulares, concretos, el análisis del devenir y del ser va a contraponer un realismo de la esencia? ¿Y la ontología aristotélica va a unirse por este medio al platonismo que suponía ya la epistemología?⁸

II. EL SER IDEAL. LA IDEA MORAL

A partir de lo dicho, ya sea: la idea como el ser propio y verdadero de las cosas; o, el planteo que establece que la esencia implica necesariamente existencia, y que la existencia se da en el plano de la realidad concreta, lo que en última instancia determina que algo es lo que es a partir de su adecuación a lo universal. Por ambos caminos arribamos a la misma conclusión, podemos ir de lo universal a lo particular, o por el contrario de lo particular a lo universal (deducción - inducción).

Con cualquiera de los dos métodos que utilizemos, llegaremos a las mismas conclusiones, a los fines de lo que nos interesa resaltar en nuestro estudio. Lo justo, lo bueno, lo bello son en sí mismos. Porque el ser propio y verdadero de las cosas son las esencias, o porque el acto singular y concreto al que denominamos justo, bueno o bello, lo es por su adecuación a los conceptos universales, únicos, imperecederos y eternos de justicia, bondad y belleza.

Es a partir de la existencia de estas sustancias inmateriales, el ser ideal, que podemos concebir el ser de la idea moral. La cuestión se reduce a la existencia o no de esta idea moral, que representa los valores a realizar en el orden jurídico.

"Por de pronto, es necesario precisar el problema. Todo concepto que formamos alude por su contenido a un objeto; con cada proposición (juicio) que formamos acerca de un objeto atribuimos o negamos a dicho objeto una determinada propiedad. El concepto es adecuado cuando recoge las notas reales o internas relaciones esenciales del objeto mentado,

⁸ MOREAU, *op. cit.*, págs. 80, 93 y 94.

*y el juicio es verdadero cuando atribuye al objeto propiedades que realmente posee. Todo hombre en poder de la necesaria capacidad mental debería llegar al mismo resultado cuando se concentra en determinado objeto. Nuestro problema consiste en averiguar si es posible formar tales conceptos y juicios válidos acerca de las cosas morales"*⁹.

Esta cuestión se discute desde la más remota antigüedad. Trasímaco afirma: "La justicia consiste en lo que le conviene al poderoso". Esta posición —con los mismos u otros aditamentos— se fue reiterando a lo largo de la historia, a la que denominamos nihilismo o relativismo ético, nos plantea la imposibilidad de obtener un concepto moral universal. Es decir, válido para todos los tiempos y para todos los lugares.

Vamos a adelantar nuestra opinión, que terminaremos de desarrollar en el capítulo siguiente. Afirmamos la existencia de los valores en sí mismos. Por su particular naturaleza éstos no se dan en el espacio, no caen bajo nuestros sentidos, sino que los captamos, los develamos a partir de la dimensión espiritual del hombre, a partir de su conciencia jurídica. La sustancia inmaterial de que están compuestos los valores nos impide tocarlos, verlos, olerlos, oírlos, gustarlos. Pero esta limitación impuesta por la naturaleza propia de que se componen, no impide de modo alguno reconocer la existencia objetiva (en sí) de los valores morales. Es un error considerar que el fenómeno psíquico de pensar en un valor le otorga valor y una particular forma de existencia a ese valor que pensamos, ya que nuestra actividad de captar un valor, no modifica su esencia objetiva, que se mantiene incólume más allá del particular estadio de evolución en que nos encontremos, que nos permitirá captarlo con mayor o menor plenitud.

La idea moral del Derecho se compone de los valores a realizar por el orden jurídico. Estos valores que consisten en porciones del ser ideal, tienen, como hemos afirmado, una existencia objetiva, excluyente de la conciencia que los capta. El hombre, esa maravillosa armonía de materia y espíritu que integra como unidad humana la vida y el destino de los pueblos, penetra en el universo de los valores a partir de su dimensión espiritual, y la medida de la penetración está indisolublemente atada al estadio de evolución en que se encuentra. Es por eso un error afirmar que en virtud de los cambios en las convicciones sobre los valores que cada generación tiene implica que éstos no son objetivos ya que cada uno entiende por ellos lo que quiere, o lo que puede. Nada más alejado de la verdad. En realidad la sociedad en su conjunto, mediante las penetraciones individuales en el ser ideal, va develando los valores, y a partir de un principio primor-

⁹ COING, H., *Fundamentos...*, págs. 109-110.

dial: la irreproducibilidad de fases éticas superadas, y la permanente evolución del hombre gobernada por la constante búsqueda de formas de convivencia más justas, es que, de generación en generación el hombre va develando con mayor plenitud cada uno de los valores con los que luego impregna su realidad cotidiana.

III. LOS VALORES A REALIZAR EN EL ORDEN JURÍDICO

Los valores morales captados por el hombre, a partir de su dimensión espiritual, nos obligan, nos exigen adecuar nuestra conducta a ellos, en la permanente búsqueda de la perfección, que en última instancia implica interpolar, a cada paso con mayor plenitud, la justicia en nuestras relaciones cotidianas. El Derecho nos plantea la adecuación de la conducta del hombre a lo que determinan sus normas. Las posiciones del Derecho pretenden interpolar lo justo en las relaciones humanas, de acuerdo a la permanente búsqueda de la perfección. La idea moral del Derecho implica pretender realizar la justicia y la dignidad personal del hombre en la sociedad concreta de que se trate.

Justicia y dignidad del hombre son los valores que deben orientar y realizar todo el orden jurídico. De ellos, y en la medida de su más acabada comprensión, surgen el resto de los valores que realiza el Derecho.

La justicia y la dignidad del hombre son valores, y como tales son esencias objetivas que el hombre puede captar correcta o incorrectamente, pero son independientes de la conciencia que los atrapa, y su particular existencia ideal trasciende el fenómeno psíquico de la captación.

*"Los valores son esencias trascendentes, absolutas, alógicas y, como tales, aprehendidas no por vía intelectual sino irracional, en la intencionalidad de los sentimientos espirituales, es decir, de la persona. Los valores no son, simplemente valen; están desdibujados de consistencia ontológica, pero trascienden la pura subjetividad y son independientes del sentimiento que los aprehende y se imponen al sujeto de un modo universal y absoluto y, en tal sentido, son trascendentes a la persona. Sólo en la persona los valores valen y manifiestan su consistencia trascendente a la misma... los valores, sin embargo, son reales e identificados con el ser. La solución tomista sigue siendo verdadera hoy como antes. Pero el valor sólo cobra todo su sentido ontológico en la doctrina de la participación"*¹⁰.

¹⁰ DERISI, op. cit., págs. 156-157.

Hemos transcritto el párrafo que antecede con el fin de ilustrar la enorme complejidad que surge de comprender cabalmente el problema de la ontología de los valores. Este autor nos plantea el ser de los valores, a partir de la teoría de la participación. Esta cuestión excede en mucho nuestro objetivo para esta parte del libro, por eso, nos conformamos con afirmar la existencia de los valores con absoluta consistencia ontológica en sí; sin embargo, su existencia plena no se da en el terreno de nuestra realidad. Los valores existen como idea en estado universal, nosotros conocemos en nuestra realidad sus manifestaciones singulares. Atribuimos a tal acto el carácter de justo, por su adecuación a la idea universal de justicia.

Los valores que tiende a realizar el orden jurídico son: la justicia, en su más cabal comprensión, como valor de valores, como virtud de virtudes; la dignidad del hombre; la igualdad, el orden, la paz, la seguridad, la libertad, entre otros, entre muchos otros valores que el hombre ha captado o que irá captando o perfeccionando su aprehensión mediante la conciencia jurídica y la constante evolución del mismo.

Con respecto a la libertad, que hemos incluido entre los valores a realizar en el orden jurídico, ha sido porque consideramos que en la formación del abogado tiene mayor importancia la convicción de que la libertad es un valor esencial del orden jurídico que las consideraciones ontológicas que impiden considerarla un valor.

*"Como se habrá observado, la libertad no aparece en la tabla de valores y ello se debe a que no es un valor jurídico puro. En efecto, teniendo en cuenta que la libertad es una sustancia misma de la conducta, al punto de que existencialmente son la misma cosa, se comprenderá la imposibilidad de que algo sea, al mismo tiempo, una cosa y una cualidad de dicha cosa. Por tal razón, siendo la libertad la esencia de la conducta, mal puede ser una cualidad de la conducta misma. Esta elemental consideración ontológica impedirá pues toda confusión"*¹¹.

Esta posición es absolutamente inobjetable, sin embargo consideramos que por razones didácticas y fundamentalmente de formación profesional, la libertad debe ser considerada un valor a realizar, proteger y resaltar por el orden jurídico. Ya que esto no se da inmediata y necesariamente junto al obrar humano, sino que es una tarea cotidiana del hombre su conquista y consolidación.

¹¹ TORRÉ, A., Introducción..., cit., pág. 228.

IV. LA CONCIENCIA. ESTRUCTURA DE LA PSIQUIS

La ciencia de la psicología distingue en la estructura psíquica del hombre dos capas. La capa de la conciencia y la capa de la inconsciencia.

Freud nos dice: *"El único punto de apoyo de nuestras investigaciones ha sido el carácter de conciencia o inconsciencia. Pero hemos acabado por ver cuán múltiples sentidos puede presentar este carácter"*¹².

La capa consciente *"Dirige la vida, pone fines y decide entre diversos motivos, por el recuerdo y la conciencia de futuro, los cuales liberan de la prisión en el instante presente, por la inteligencia que abstrae de lo presente, objetiva y crea así distancia. En esta capa arraiga y se funda el hecho de que el hombre sea un ser racionalmente determinado capaz de elegir entre los motivos que se le presentan, y no dominado por el instinto como el animal"*¹³.

En la capa inconsciente, la de la personalidad profunda, deben distinguirse diversas "capas". *"La de los procesos vitales orgánicos, de los instintos y reacciones animales, del comportamiento lúdico infantil, y finalmente, de lo anímico o vida del sentimiento"*¹⁴.

El Derecho se dirige a la capa consciente de la personalidad humana. *"El Derecho es ordenación previsor y valorativa de la vida social; se encuentra pues en el amplio ámbito de la configuración consciente de la vida y de la existencia por el hombre"*¹⁵.

El hombre por sus peculiares características que conforman su naturaleza, puede superar sus instintos, elevarse por sobre ellos (vid. Cap. I). Los animales que viven en colectividad (v.gr., abejas, hormigas) no crean el orden en que viven. Sino que les viene a ellos por el instinto. Están previamente determinadas por el instinto, por lo que, en cada nuevo integrante de la especie, comienza todo otra vez, en una reproducción casi perfecta de lo hecho por sus antecesores. En cambio, el hombre crea su orden social (sin perjuicio de que la existencia de la sociedad corresponda a la propia esencia de la naturaleza humana) lo mantiene y perfecciona día a día, a partir de decisiones conscientes, lo que denota una clara *"Expresión de la libertad humana de la espontaneidad de la vida frente a la vinculación del animal al instinto y frente al crecimiento vegetativo de la planta"*¹⁶.

¹² FREUD, S., *El Yo y el Ello*, Orbis, Barcelona, 1984, pág. 16.

¹³ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 63.

¹⁴ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 63.

¹⁵ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 63.

¹⁶ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 64.

En cada nuevo hombre no comienza la historia, sino que continúa en él. Cada hombre es portador de las vivencias, experiencias, pareceres y convicciones de los miles de millones de hombres que estuvieron antes. Y a su vez, cada hombre transfiere sus propias convicciones a los que le siguen, por lo que la construcción del orden social corresponde a esa suma infinita de pareceres individuales que conforma el conjunto de convicciones de la comunidad de que se trate.

Refiriéndonos ya a nuestro objeto de estudio, el Derecho, vemos que éste se dirige al hombre consciente, al hombre despierto, a aquél que actúa con responsabilidad, lo que implica la libertad en la determinación de la conducta a seguir. Por eso el Derecho se refiere a la capa consciente de la estructura psíquica del hombre. Pero lo dicho no inhibe de que en el contenido concreto del derecho que se trate, influya decisivamente en su conformación la capa inconsciente o de la personalidad profunda. *"El proceso de formación del Derecho es decisión consciente. Pero el contenido que el hombre dé a su orden social, las tendencias que inhiba y las que favorezca, resultan del sentimiento y de las tendencias vivas en su alma y de la energía y jerarquía de éstas. Ellas suministran el material sobre el cual elige la decisión consciente que lo forma y configura, y la intensidad de instintos y sentimientos influye en el contenido de la decisión. En este sentido no es comprensible el orden jurídico sino partiendo del contenido sentimental y volitivo del hombre, igual que las demás creaciones de su espíritu"*¹⁷.

Por lo dicho, podemos concluir que la conciencia jurídica es *"Una conciencia de los valores que organizan el orden jurídico y de las reglas fundamentales resultantes"*¹⁸. La conciencia jurídica así entendida es un sentimiento jurídico hecho consciente.

"La diferencia que media entre la aprehensión y realización de estos bienes de los seres finitos materiales y del ser espiritual o personal del hombre, es que éste no sólo es capaz de aprehender y realizar el bien, como aquéllos, sino de aprehenderlo formalmente como bien, como ser apetecible trascendente, y de proponérselo y realizarlo libremente en cuanto bien. El bien sólo se devela como tal ante la inteligencia y sólo es realizable formalmente como bien por la libertad, o en otros términos sólo se manifiesta y se realiza en cuanto tal por el espíritu y, en tal sentido, sólo el hombre es capaz de ver o apreciar el bien y de realizarlo como bien, de apropiarse de él por la conciencia y la libertad. Los demás seres

¹⁷ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 65.

¹⁸ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 67.

o no aprehenden el bien o, a lo más, lo aprehenden concretamente sin descubrirlo en su formalidad de tal, y lo realizan siempre necesariamente, es decir, con un determinismo impreso en su actividad —leyes físicas, químicas, biológicas, instintivas— y no son capaces de descubrirlo ni elegirlo libremente en cuanto tal. Porque sólo el hombre es capaz de conocer el ser como ser y su relación de conveniencia —o disconveniencia— con algunos de los aspectos de su ser, en que consiste el bien o valor. En efecto, el bien o valor no es sino el ser con la relación de conveniencia con otro ser, al que actualiza o perfecciona; ser aprehendido y realizado conscientemente, a saber, por la actividad espiritual de la inteligencia y de la voluntad.

*"En tal sentido, únicamente el hombre es capaz de valorar, o en otros términos de descubrir y de elegir libremente el bien como tal. Este bien develado y elegido consciente y libremente —vale decir, presente la actividad espiritual— es formalmente el bien o valor"*¹⁹.

Esta actividad de develar, de descubrir la realiza el hombre mediante la acción de su psiquis. Estos valores penetran en el hombre, o el hombre los devela por medio de la capa inconsciente, la capa de la personalidad profunda. Y es en el tránsito de estos valores —que se encuentran en nuestro inconsciente— hacia la capa consciente de la personalidad, donde conocemos el valor develado. *"Todo nuestro conocimiento se halla ligado a la conciencia. Tampoco lo inconsciente puede sernos conocido si antes no lo hacemos consciente"*²⁰.

Por eso dijimos que la creación del Derecho, el establecimiento de cualquier posición de Derecho, corresponde a la capa consciente del hombre, pero su contenido le viene al hombre de las profundidades de su personalidad. Como consecuencia de esa incesante tarea de develar, de captar los valores, y mediante complejos mecanismos psíquicos hacer conscientes los valores que arraigan en las capas más interiores de su inconsciencia, atrapados en ese espacio psíquico a partir de la búsqueda individual y de la transferencia de valores que la sociedad en su conjunto efectúa con cada nuevo individuo que la compone.

Estos valores que llegan a la capa consciente, lo hacen con toda su carga de exigencias, vale decir, que los valores exigen en conciencia, adecuar su conducta a ellos.

Coing nos plantea que existen diversas corrientes que intervienen en la conformación de la conciencia jurídica.

¹⁹ DERISI, *op. cit.*, pág. 158.

²⁰ FREUD, *El Yo...*, cit., pág. 16.

Una de ellas, las percepciones y tendencias axiológicas que actúan como fuerzas motoras y organizadoras del orden jurídico, donde encontramos los deseos de orden, de paz y de seguridad (ver Cap. II, Rasgos del orden jurídico) que se encuentran íntimamente enlazados con el hombre. Éste quiere asegurar su vida frente a las eventualidades que el futuro pueda depararle.

También encontramos aquí las tendencias morales del Derecho, el sentimiento de derecho, que nos exige respetar los derechos presentes en el otro con un criterio recíproco, es decir, que se respeten los derechos presentes en cada uno de nosotros. *"El sentimiento de derecho actúa en la conciencia y reacciona con sentimientos de disgusto no sólo a las lesiones de la posición jurídica del propio sujeto, sino también a las lesiones sufridas por el Derecho en la persona de otro"*²¹. Este sentimiento de derecho importa una profunda vocación a la igualdad.

En la generalidad de los casos —observable en la realidad cotidiana— la violación al sentimiento de derecho produce reacciones violentas, esto se debe a que en ellos se corporiza una intensa energía anímica.

Otra de las corrientes planteadas por el mismo autor se refiere, a aquélla *"que se encuentran en la base misma de los hechos y los procesos sociales en cuestión, influyendo así, naturalmente, en el contenido concreto del Derecho"*²².

Aquí encontramos un conjunto de aspiraciones, tendencias y sentimientos que subyacen en el material jurídico concreto. La voluntad de poder, el instinto de sumisión y la necesidad de contacto, obran en la conformación del grupo humano (v.gr., creación de sociedades, corporaciones, asociaciones, clubes, la familia, el matrimonio, etc.).

El derecho de propiedad se encuentra íntimamente ligado al sentimiento de alegría que causa la posesión. Imaginemos que la propiedad nos produjera a cada uno de nosotros un profundo sentimiento de insatisfacción, no habría necesidad de regularla por vía del Derecho, ya que nadie tendría interés en ser propietario. La aspiración de libertad subyace en todas las normas jurídicas que la protegen, si el hombre no pretendiera la libertad, no existirían las normas que la protegen. La tendencia de realizar valores morales, la emoción que surge frente a lo bello, lo hermoso, lo santo, lo sagrado, etcétera.

²¹ COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 69.

²² COING, H., *Fundamentos...*, cit., pág. 67.

"El amor propio determina el carácter de la reacción primaria a la lesión de derecho: la venganza... por eso la compensación de la lesión del Derecho es satisfacción de la voluntad de venganza" ²³.

El espíritu de grupo es de gran importancia para la estructuración del orden jurídico. Cada hombre se siente miembro de una familia, una nación, una religión, etcétera. La lesión al grupo se siente como lesión a cada uno de sus integrantes, y exige las mismas y aún mayores reparaciones que la ofensa personal. El espíritu de grupo se imprime en la conciencia jurídica con gran fuerza (v.gr., disposiciones penales sobre traición).

Esta conciencia jurídica es una conciencia que se desarrolla en cada grupo humano. En la continua interacción de los individuos entre sí, y de éstos con el grupo se forma la conciencia jurídica. De la interacción de los individuos entre sí y de éstos formando al grupo surgirán aquellos valores que el conjunto de hombres consideran importantes y pospondrán aquéllos menos urgentes. De aquí surge una estrecha relación entre la estructuración de la conciencia jurídica y la evolución. Como hemos dicho, lo único que permanece constante en el devenir histórico de la humanidad es su propia evolución, todo cambia día a día; pero esta evolución, obra de la naturaleza humana, no actúa ni arbitraria ni caprichosamente, sino que su orientación se encuentra determinada por la búsqueda permanente de formas de convivencia más justas, en última instancia la evolución del hombre está gobernada por la justicia. En este proceso de cambio permanente, con las bajas y altas que, naturalmente, se producen en cada grupo social, cada uno de los individuos internalizará los valores que el estadio evolutivo de la sociedad de que se trate le permite develar.

Esta conciencia jurídica que cada uno de los individuos desarrolla a partir de hacer consciente los valores descubiertos en las capas más profundas de su personalidad, se orienta a la convivencia del hombre en la sociedad. Es una conciencia *"de valores, un saber acerca de la existencia de determinados valores en la vida social, y una conciencia jerárquica que ordena y articula esos valores, los jerarquiza y fija así cual es el lugar que cada uno debe ocupar en la vida social... La jerarquía de valores, viva en la conciencia del individuo, se funde también con los demás elementos de su conciencia jurídica. Del mismo modo que la conciencia decide qué tendencias deben prevalecer en la vida del individuo, así también decide la conciencia jurídica cuáles son las tendencias que deben predominar en la vida social"* ²⁴.

²³ COING. H., *Fundamentos...*, cit., pág. 70.

²⁴ COING. H., *Fundamentos...*, cit., págs. 74-75.

Sobre este tema de la jerarquía de los valores dentro de la conciencia jurídica, corresponde hacer un comentario. Cuando coincidimos con Coing en la existencia de una jerarquía de valores que los ordena y articula y de esta manera fija el lugar que corresponde a cada uno, no nos referimos a aquéllos que podríamos llamar puros: la justicia, la dignidad del hombre, la igualdad, la libertad, la seguridad, la paz.

Al afirmar que la conciencia jurídica es una conciencia jerárquica que ordena los valores, estos valores los entendemos como "valores operativos", es decir, aquéllos que se refieren a la realización más acabada y plena de los otros (los valores puros). Por ejemplo, en una sociedad puede discutirse si para realizar más acabadamente (de acuerdo al estadio de evolución que le corresponda) el valor de la dignidad de la persona del hombre, hay que poner más énfasis en los llamados derechos sociales, o en los derechos políticos, o en ambos a la vez. Puede plantearse la preeminencia del individuo o la preeminencia de la sociedad. Esta discusión es legítima, porque corresponde a las posibilidades efectivas del grupo de interponer esos valores descubiertos y develados por la conciencia en el terreno de la realidad. Aquí es precisamente donde los jerarquiza, y en base a esa jerarquía que otorga determinará qué tendencias deben predominar en la vida social.

Pero la cuestión es distinta cuando pretende discutirse sobre la jerarquía de aquellos valores que denominamos puros. Aquí podría preguntarse ¿qué es más importante: la seguridad o la justicia? ¿la libertad o la justicia? ¿la igualdad o la justicia? En estas situaciones no existe una jerarquía de valores, sino que hay un ensanchamiento del valor justicia, al incorporar en la captación de ella misma la captación más plena de los otros valores. Queremos decir que no existe la seguridad, la paz, la libertad, la igualdad sin justicia. Es absolutamente ilegítimo plantearse que por diversas circunstancias históricas, en determinada sociedad debe prevalecer, por ejemplo, la seguridad a la justicia, o la libertad a la justicia. Ya que ningún valor de los citados se realiza sin la concurrencia de los otros. Es decir, no hay libertad sin paz y seguridad; no hay igualdad sin seguridad y libertad, etcétera.

Ocurre, que en última instancia se produce un ensanchamiento del valor justicia que los abarca a todos, que los alberga a todos. Y la justicia sólo se perfecciona mediante la realización de los otros valores (libertad, igualdad, dignidad, paz, seguridad).

Para concluir, decimos, que la conciencia jurídica actúa como una espiral, que a cada giro abarca una mayor cantidad de valores, que a su vez permite tener una más cabal captación de los valores antes develados. Estos giros son producidos por la evolución del hombre en su constante búsqueda.

queda de formas de convivencia más justas. En el centro de la conciencia, desde el cual se desarrolla este fenómeno de crecimiento en espiral, se encuentra la justicia y la dignidad moral del hombre. A cada nuevo giro de la evolución se produce un ensanchamiento de la justicia que permite abarcar nuevos valores y realizar más acabadamente los ya conocidos, lo que redundará en una mayor y mejor comprensión de la justicia.

V. LA CONCIENCIA JURÍDICA COMO FUENTE DEL DERECHO

Hemos dicho que la creación del Derecho corresponde a la capa consciente de la personalidad humana, pero el contenido del Derecho creado le viene al hombre de las capas de su personalidad profunda o inconsciente.

El término fuente del Derecho se lo utiliza para designar diversas cuestiones. En el presente trabajo lo utilizaremos en su sentido más difundido, que se refiere a las fuentes formales y materiales.

Fuentes formales. Entendemos por tales, las diversas maneras en que se han manifestado y exteriorizado, a lo largo de la historia, las normas jurídicas.

Fuentes materiales. Se entiende por tales, el contenido de la norma creada, las razones, finalidades o valores que se persiguen y que determinan la creación de la norma.

Con lo dicho sobre el tema de fuentes del Derecho alcanza para esta parte de la obra, porque nos interesa resaltar que la única fuente material del Derecho es la conciencia jurídica sumada al conocimiento de la naturaleza de la cosa.

VI. LA CONCIENCIA JURÍDICA Y LA VALIDEZ DEL DERECHO. SU OBLIGATORIEDAD

El positivismo jurídico nos plantea la validez del Derecho a partir de que la norma pertenezca a esa estructura que denominamos orden jurídico, sin ningún tipo de examen ulterior.

En la obra *Teoría Pura*, Kelsen nos explica la validez de la norma de la siguiente manera: "Otra cosa sucede con las normas jurídicas. Su validez no resulta de su contenido. El Derecho puede tener no importa qué contenido, pues ninguna conducta humana es por sí misma inepta para convertirse en objeto de una norma jurídica. La validez de dicha norma no se encuentra afectada por el hecho de que su contenido se halle en oposición con un valor moral u otro cualquiera.

*"Una moral jurídica es válida si ha sido creada de una manera particular; es decir, según reglas determinadas y de acuerdo con un método específico. Su positividad reside en el hecho de que proviene necesariamente de un acto creador y es así independiente de la moral y de todo sistema normativo análogo. Las normas del derecho natural y las de la moral son, por el contrario, deducidas de una norma fundamental que en razón de su contenido, está considerada como si apareciera inmediatamente evidente, como una emanación de la voluntad divina, de la naturaleza o de la razón pura"*²⁵.

Esta concepción puede llevar a considerar como integrante del Derecho cualquier norma, sólo se requiere que sea puesta de acuerdo a un método específico.

Llevando esta posición a sus últimas instancias, podemos imaginar una norma que determine que los hombres una vez incapacitados para el trabajo, en razón de la edad o cualquier otra circunstancia, deben morir, a tal efecto se facilitan los medios para el suicidio, y en su caso, se autoriza a determinados miembros del grupo a hacer cumplir la medida, cuando el suicidio no se efectivice en un plazo establecido. Esta norma repugna a nuestras convicciones, nadie puede legítimamente afirmar que ésta es una norma jurídica, sino que es una norma impuesta desde una estructura de poder, por un grupo de extraviados. El ejemplo es extremo, pero simplemente analicemos la legislación de la Alemania de Hitler, o la del Proceso de Reorganización Nacional, para comprender que esta hipótesis no es tan remota.

Torré, por su parte nos plantea: "*La estructura piramidal del ordenamiento jurídico, nos permite ver con claridad que el fundamento de validez de una norma ha sido establecido por los órganos y con el procedimiento prescripto por otra norma superior (validez formal), sino también cuando su contenido se encuadra en lo que dispone la norma fundante (validez material)...*es indudable que al jurista stricto sensu no le interesa el análisis de dichos fundamentos extranormativos, pues se detendrá en la Constitución que, para él, es algo así como el dogma revelado para el teólogo, pues en ella encontrarán fundamento último todas sus especulaciones dogmático-jurídicas"²⁶.

Este concepto es absolutamente contrario a lo que venimos sosteniendo en el libro. No importa que la norma tenga validez desde el punto de vista formal o material, para que sin más se la considere integrando el

²⁵ Kelsen, *Teoría Pura*, cit., págs. 136-137.

²⁶ TORRÉ, A., *Introducción...*, cit., pág. 216.

orden jurídico (vid. Cap. II, Visión de contenido y, particularmente, el transcripto Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional del 24-III-1976 y publicado en el *Boletín Oficial* el 31-III-1976).

La validez del Derecho y por ende su capacidad para obligar la conducta humana la encontramos en la adecuación del derecho positivo a la idea moral descubierta por la conciencia jurídica.

Kelsen en otra parte de la *Teoría Pura* dice: "*Si el Derecho es una técnica social utilizada para inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada, falta examinar en qué medida alcanza su fin. Puede preguntarse a este respecto por qué razones la mayor parte de los hombres se conducen de la manera prescrita por el Derecho. Ahora bien, es difícil establecer que su obediencia al Derecho esté dada por la amenaza de un acto de coacción. En muchos casos intervienen más bien motivos de orden religiosos o morales, el respeto de los usos, el temor a perder la consideración de su medio social o simplemente la ausencia de toda tendencia a conducirse de modo contrario al Derecho... La técnica específica de Derecho consiste —recordémoslo— en hacer seguir un acto de coacción visto como un mal a una conducta humana considerada como socialmente nociva, puede ser utilizada con miras a alcanzar no importa qué fin social, ya que el Derecho no es un fin, sino un medio. Desde este punto de vista, el Derecho es una técnica de coacción social estrechamente ligada a un orden social que ella tiene por finalidad mantener*"²⁷.

En el primer párrafo transcripto Kelsen penetra en un aspecto que consideramos esencial, cual es: por qué razón la mayoría, la inmensa mayoría de los hombres viven y adecuan su conducta a lo dispuesto por el orden jurídico. En el segundo, nuevamente cede ante el poder. Decir que no importa qué fin social persigue el Derecho (cuál es su finalidad, sus objetivos) y reducirlo a una mera técnica de control social basado en la coacción, es descarnarlo, a tal punto, que el orden así considerado, puede ser cualquier cosa menos un orden del Derecho.

Obsérvese la conducta cotidiana de miles de millones de hombres que conviven en el planeta. Cada uno sujeto a distintos órdenes jurídicos, cada uno portador de la cultura y valores que corresponden a su grupo social, cada uno con su particular visión religiosa. Pero hay un punto donde las coincidencias de los hombres resulta notoria. Lo encontramos en la evolución, en esa búsqueda permanente de formas de convivencia más justas. Cada comunidad con sus particularidades propias, con su idioma y su cultura, pero todas esas comunidades buscan, como si estuvieran deter-

²⁷ KELSEN, *Teoría...*, cit., págs. 73-74.

minadas por un instinto colectivo —de pertenencia exclusiva al género humano— ordenar las infinitas interrelaciones humanas y de los individuos con el grupo a la justicia.

Esto nos demuestra que el derecho positivo sólo estará seguro, en la medida de las convicciones jurídicas que más allá del Derecho puesto tengan los individuos pertenecientes al grupo, al cual se dirige ese orden concreto.

Imaginemos un conjunto de normas jurídicas puestas en nuestra comunidad contrarias a nuestras propias convicciones jurídicas. Contrarias a nuestra convicción sobre lo justo, sobre la dignidad del hombre, sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la paz, sobre la seguridad, etcétera. Es posible, que durante los primeros tiempos adecuemos nuestras conductas a esas normas, por temor a la sanción. Pero luego, a medida que el tiempo transcurra, es absolutamente seguro que las violaciones a la norma serán más que el acatamiento a las mismas. Esta afirmación es un hecho hartamente probado por la historia. Y, es así, porque resulta imposible establecer controles estrictos sobre cada individuo. No es posible quitarle al hombre la totalidad de su libertad, porque para ello es necesario quitarle a su vez la vida. El saber del pueblo ha acuñado un refrán: "hecha la ley, hecha la trampa". No es posible controlar la conducta de cada hombre en su totalidad, porque más allá de las dificultades fácticas que ello conlleva, nos topamos con otra, que es que el que controla a su vez debe tener otro control, y así, sucesivamente hasta el infinito. Por esto, el Derecho vigente en un lugar y tiempo determinado sólo es posible en la medida que sea reflejo de las convicciones jurídicas de los individuos que integran el grupo, al cual se dirige. En esta convicción cabe preguntarse: si nosotros no matamos por temor a la eventual sanción que determina la legislación penal, o simplemente no matamos porque matar es malo.

La conciencia jurídica es, entonces, el sustento necesario de la eficacia de la norma y por ende de su vigencia efectiva.

La obligatoriedad del Derecho (vid. Cap. II) descansa en última instancia en la concordancia de éste con los valores develados y descubiertos por la conciencia jurídica. Ya que la norma injusta no obliga, no vincula la conducta humana a sus prescripciones. Nadie está obligado a cometer una injusticia ni a soportarla. Y, es el irrenunciable deber de los hombres, luchar sin reservas para lograr la interpolación de lo justo en su realidad cotidiana, como aporte personal a la magna tarea de la evolución del género humano.

VII. FALSA CONCIENCIA

Hemos analizado ya el tema de la jerarquía de los valores, y dijimos que no hay valores mayores y valores menores, sino que existe un ensanchamiento, una mayor comprensión del valor justicia.

Por otro lado, el hombre, como punto de penetración de los valores en la realidad, constantemente persigue una mayor y mejor captación de esos valores (evolución). Pero pareciera que los valores en su plenitud actúan como el horizonte. Nos acercamos un paso y éste, a su vez, se aleja un paso.

Cabe preguntarse si en algún estadio de la evolución el hombre captará plenamente el valor justicia, o por el contrario, este valor actuará como orientador de la evolución sin lograrlo captar jamás en su plenitud. Este interrogante supera con creces el objetivo de este libro, tan sólo podemos agregar al interrogante planteado, sin pretender agotarlo, que el hombre persigue la perfección, sin que su destino sea necesariamente obtenerla. Lo que sí podemos afirmar es que nuestro destino es la búsqueda, no sabemos aún, si éste incluye la obtención del objetivo deseado.

En esta permanente búsqueda a la que estamos determinados, nuestro camino no siempre es lineal, por el contrario, está lleno de marchas y contramarchas, de avances y retrocesos, de logros y fracasos. Esto se debe a que es el conjunto de la humanidad en el decurso el que logra alcanzar un nuevo estadio de evolución, en cambio cada uno de los individuos se encuentra inmerso en su realidad concreta, plena de inseguridades, de temores, de creencias e intereses específicos que pueden llevarnos a convicciones equivocadas, es lo que denominamos falsa conciencia.

La falsa conciencia es una incorrecta captación de los valores. Que tiene dos orígenes diversos. Ellos son: el primitivismo y el ideologismo.

Primitivismo. Es una insuficiente captación de los valores, de acuerdo al estadio de evolución del grupo de que se trate, por ejemplo: la esclavitud. Antiguamente se consideraba legítima la institución de la esclavitud (había una insuficiente captación del valor de la persona del hombre). En la medida y al ritmo de la evolución del hombre, esta insuficiente captación se modifica, penetrando más en la esencia del valor, lo que determina un paulatino, pero persistente y permanente, cambio en la sociedad y sus instituciones. En el caso del ejemplo, un largo recorrido hasta su total abolición.

Ideologismo. Es una falsificación de valores, que se da cuando en un grupo social, sobre la base de ideologías falsas, se establecen valores a realizar por el orden jurídico, que no lo son. Por ejemplo, la superioridad

de la raza, establecida por el nazismo. O la posición de priorizar la seguridad a la justicia en la Argentina de 1976 a 1983.

También podemos plantear como ideologismo la falsa discusión sobre la preeminencia del individuo o la sociedad. Asimismo entendemos como ideologismo ver a la lucha de clases, o a la acumulación de riquezas como motor de la historia.

En resumen, hay falsa conciencia jurídica en base al ideologismo cuando existe una falsificación de valores a partir de determinada ideología.

CAPÍTULO VI NATURALEZA DE LA COSA

I. CONCEPTO

Por naturaleza de la cosa entendemos, en principio, la particular forma de ser que tienen las cosas. De las propias singularidades y características que hacen que una cosa sea lo que es y no otra, se determinan las particularidades que le son propias. Estas particularidades no surgen de una convención entre los hombres, como por ejemplo, el sentido de circulación en una calle, donde nada impide, más que el acuerdo, que el sentido de circulación sea el contrario, sino que es la propia naturaleza de las cosas la que determina esas diferencias. Así, por ejemplo, el distinto tratamiento que el orden jurídico determina con respecto a los bienes muebles e inmuebles, encuentra su sustento en la distinta naturaleza que les viene de sí. Obviamente resultan distintos un lote de terreno y una biblioteca. También podemos decir que una biblioteca y un escritorio son distintos, sin embargo, los elementos que poseen cada uno que lo hacen distintos, no son de tal magnitud como para que el orden jurídico determine un tratamiento distinto sobre su propiedad y transmisión, tanto la biblioteca como el escritorio tienen desde el punto de vista jurídico un trato igual. Y, en el mismo sentido, un lote de terreno y un departamento son, a su vez, también distintos, sin embargo, a ambos les corresponde los mismos recaudos en cuanto a la relación entre ellos y las personas, esto es así, ya que tanto el lote de terreno como el departamento, ambos, son inmuebles.

Es decir, el orden jurídico debe tomar las particularidades que surgen de la naturaleza de las cosas para poder establecer ese orden en las relaciones sociales. De lo contrario, el orden del derecho se tomaría impracticable en aquellos aspectos en que contradiga a la naturaleza de las cosas. Obsérvese que en el proceso de propiedad del viejo derecho romano se exigía la presencia de la *res litis*, sin embargo, se excluía de esta exigencia a los bienes inmuebles, por su propia naturaleza, ya que si se exigía la presencia ante los estrados judiciales de un fundo, por ejemplo, resulta una

exigencia absurda e imposible de cumplir, ya que contradice la naturaleza misma de las cosas.

La particular forma de ser del hombre, sus características psíquico-somáticas, la forma de nacer, el desarrollo humano, su niñez, el sentimiento del amor paternal, del amor filial, su capacidad, su voluntad, sus instintos, sus tendencias, su vocación de trascendencia, su búsqueda de la verdad; su vocación de conocimiento, en fin, todas aquellas cuestiones que hacen que el hombre sea lo que es, tienen relevancia esencial para el orden del Derecho.

Observemos como ejemplo el instituto de la capacidad; nuestro Código Civil en su artículo 54 nos dice, refiriéndose a la capacidad de las personas: "Tienen incapacidad absoluta: 1) Las personas por nacer; 2) Los menores impúberes; 3) Los dementes; 4) Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito". En el artículo 128 dice: "Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad, el día en que cumplieren 21 años, y por su emancipación antes que fuesen mayores".

Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante, quedando a salvo al respecto las normas del derecho laboral. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia, sin necesidad de previa autorización.

En los supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer libremente los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos.

El artículo 141 dice: "Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes".

El artículo 152 bis dice: "Podrá inhabilitarse judicialmente:

"1) A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.

"2) A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que el ejercicio pleno de su capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio.

"3) A quienes por la prodigalidad de sus actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio... Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación.

"Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos.

"Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso".

Todas las normas que hemos transcripto se refieren a situaciones en las que algunas personas se encuentran en notoria inferioridad, en una clara desigualdad con respecto a los otros hombres. Esta desigualdad que surge de la naturaleza misma de las cosas, de la propia y particular naturaleza de la persona humana, determina un trato distinto, para lograr que el resultado final de la ecuación sea de un tratamiento igual. Para superar esta desigualdad natural, que surge de la propia naturaleza del hombre, el orden jurídico, por ejemplo, ha creado el instituto de la capacidad, en donde aparece la obligación de nombrarle a cada incapaz un representante para que actúe con él y, en algunos casos extremos, por él. De esta manera, el orden jurídico logra salvar las diferencias que la propia naturaleza ha puesto y permite obtener como resultado final de las múltiples relaciones sociales que pueden realizarse, un tratamiento igualitario de las partes en cuestión.

Asimismo, podrá discutirse si la plena madurez de las personas se adquiere a los veintiún años, o a otra edad, o para cada individuo ese límite es impreciso. Lo que sí podemos asegurar es que nadie se acuesta incapaz, y se despierta plenamente capaz, por el mero cumplimiento de una fecha preestablecida. En este caso es menester recordar que el Derecho se refiere a la generalidad de las personas, no a alguien particular, por lo que determinar una edad en la que una persona comienza a ser plenamente capaz, y por lo tanto responsable de sus actos, es sumamente discutible y problemático, que mucho tiene que ver con las creencias y pautas culturales de cada grupo. Lo que sí resulta obvio es que los menores, año más o año menos, se encuentran en una situación desigual. Hecho que surge de la naturaleza misma de las cosas, y de allí el sustento para el tratamiento desigual que determina el orden jurídico. Lo mismo ocurre con los otros tipos de incapacidades a que se refieren las normas que hemos transcripto.

También, vemos en otros aspectos de la vida social la predeterminación de las instituciones que realiza la particular naturaleza del hombre. Por ejemplo, si no existiera la diferencia de sexos y su especialización en la concepción de un nuevo ser humano, no cabría hablar del matrimonio, por lo menos tal cual lo conocemos. Si no tuviéramos profundamente arraigado en nuestra personalidad la necesidad de asegurar la vida frente a las eventualidades del destino, y el poseer bienes materiales, en alguna medida satisface este sentimiento de seguridad, se tornaría inimaginable

cualquier sistema de propiedad. Sin el sentimiento del honor, del propio valor de cada uno, no existiría una acción de calumnias e injurias. Los conceptos de culpa, alevosía, negligencia, premeditación, no tienen sentido alguno aislándolos de la psiquis humana.

Este concepto de la naturaleza de la cosa, que se refiere a la particular forma de ser que tienen las cosas, y entre esas cosas, ya hemos visto, a la particular forma de ser que tiene el hombre, además este concepto también incluye el universo que circunda al hombre, es decir, la particular forma de ser que tiene la naturaleza que vive y se renueva permanentemente en torno de cada hombre. El habitar este planeta con sus mares y sus desiertos, con sus montañas y llanuras. La sucesión día-noche, la duración del año, la sucesión de las estaciones. La escasez de los bienes que determina la necesidad del esfuerzo para conseguirlos, el hecho inevitable de dominar la naturaleza para extraer de ella los recursos que el hombre requiere para su sustento.

Todas estas cuestiones determinan un amplio espectro de datos otorgados por la forma de ser del universo que circunda al hombre, que el orden jurídico sólo debe reconocer. Piénsese, por ejemplo, en la unidad económica, no se requiere la misma cantidad de hectáreas en la Pampa Húmeda que en la Meseta Patagónica o en la Puna. O, las normas sobre pesca, con las que se pretende preservar el recurso de la depredación que implica no tener en cuenta su ciclo natural. La legislación sobre las aguas para riego, que pretende su utilización racional, de acuerdo a la disponibilidad natural de la misma. Las normas sobre preservación ecológica, sobre utilización de agroquímicos, sobre forestación, sobre conservación de recursos naturales tanto renovables como no renovables, en fin, el orden jurídico debe respetar esa particular forma de ser del universo que nos rodea.

Otro elemento que forma parte del concepto que estamos estudiando es la particular naturaleza de la tecnología, de todas las técnicas que la capacidad intelectual del hombre ha generado. La técnica determina especiales modos de comportamiento, a partir de sus características propias.

De la naturaleza misma de la técnica del automóvil surge la forma en que debe conducirse. La máquina, cualquier máquina, determina la forma en que debe ser utilizada. La imprudencia que determina no observar la conducta que impone la regla técnica deviene en una responsabilidad jurídica. Imaginemos, por un momento, que la tecnología creada por el hombre permite construir un automóvil que puede circular a la alta velocidad, trescientos kilómetros por hora, por ejemplo, y que se detiene automática e inmediatamente cuando cualquier objeto se interpone en su camino, sin riesgo alguno para sus ocupantes, como para los transeúntes, ni

genera riesgo adicional para la comunidad. En este caso no tendría sentido limitar la velocidad en las ciudades a cuarenta kilómetros horarios.

Esto es así, porque lo que la norma jurídica castiga o prohíbe, es la violación a lo que surge del correcto uso de la tecnología disponible. Los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo, los desastres ecológicos, indican la violación de las normas que surgen de la cosa técnica.

Por último, existe otro elemento para concluir con el concepto de la naturaleza de la cosa, al que Coing denomina la objetividad propia e interna de los diversos ámbitos de la actividad.

Así, resulta que el juez debe ser imparcial, ajeno a las partes que someten el conflicto que tienen a su jurisdicción. Esto surge de la naturaleza propia, de la legitimidad propia de la actividad judicial. El juez debe ser absolutamente independiente de las partes, de lo contrario, el accionar del juez estaría en franca contradicción con los postulados esenciales que surgen de la objetividad propia de la actividad de juzgar.

En el mismo sentido, el comerciante actúa con ánimo de lucro, es propio de él lucrar con su actividad, el derecho no puede presumir la gratuidad de la actividad comercial, porque de la objetividad propia de la actividad comercial surge que ésta se realiza en procura de obtener una ganancia.

Así, también el trabajo se presume oneroso. El trabajador atiende a sus necesidades de subsistencia mediante el salario obtenido por el trabajo realizado, por lo tanto, su actividad está orientada a la obtención del salario, a obtener una retribución por el esfuerzo realizado. Como podemos observar estos principios no surgen de la claridad del legislador, sino, por el contrario, son datos previos que el legislador sólo debe reconocer como tales, ya que éstos surgen de la objetividad propia, en nuestro caso, de la actividad laboral, que determina que el trabajo se presuma oneroso.

Un médico no puede asegurar a su paciente que va a evitar la muerte, tan sólo le garantiza el acceso a la técnica y a la ciencia médica. En el mismo sentido, un abogado no puede garantizar a su cliente el éxito en su litigio, simplemente ofrece y garantiza la correcta defensa de los intereses en juego. Y, esto es así, porque de la naturaleza misma la actividad del médico y del abogado le impiden comprometer y asegurar un resultado específico.

Por el contrario, un constructor, al que se le encomienda la construcción de una vivienda, por ejemplo, garantiza el resultado final de su actividad, es decir, una vivienda de las características previamente determinadas.

Así, resulta que la objetividad propia de los diversos ámbitos se la actividad manifiestan una legalidad propia e interna, de los actos a los que

se refiere, a los que el orden jurídico tan sólo debe recibir. Insistimos con el concepto. De la enorme posibilidad de distintas formas de relacionarse los hombres entre sí, hay algunas que por sí mismas manifiestan reglas que necesariamente deben cumplirse. En estos casos el legislador debe observar ese dato de legalidad previa a cualquier regulación jurídica, para luego consagrarlo en la legislación vigente.

De esta manera, el concepto de naturaleza de la cosa incluye en sí, la particular forma de ser de las cosas, la particular naturaleza del hombre, la naturaleza del universo que circunda al hombre, la particular naturaleza de la cosa técnica y la objetividad propia de los diversos ámbitos de la actividad. Así el concepto de: *"Naturaleza de la cosa parece ampliarse hasta convertirse en la idea de un amplio orden de las cosas sociales. Dentro de las cosas mismas parece darse ese orden que la justicia no tendría más que descubrir y respetar para proceder con seguridad... La naturaleza de la cosa parece dar a la abierta justicia los criterios o escalas que le faltaban, de tal modo que la idea del Derecho podría ampliarse hasta ser un orden concluso por apelación al orden que yace ínsito en las cosas mismas. La justicia consistiría entonces en ordenar a los hombres y a los procesos sociales en el orden jurídico por el procedimiento de adjudicarles el lugar que ya ocupan por el eterno orden del ser"*¹.

II. LA IDEA DEL DERECHO Y LA NATURALEZA DE LA COSA

Hemos definido a la justicia como el tratamiento igual de aquéllos que son iguales y el tratamiento desigual de aquéllos que son desiguales, evitando discriminaciones que no surgen de la naturaleza de las cosas.

En tal sentido vemos, por ejemplo, que el trato desigual que reciben los menores de edad, surge de la naturaleza misma del hombre, y que captado por el legislador, se intenta realizar el principio de justicia que hemos enunciado, de manera tal que en el trato desigual de aquello que naturalmente es desigual, se logra un resultado igualitario en la ecuación final de la relación. Ya que nada produce mayor desigualdad que pretender igualar, sin más, aquello que naturalmente es desigual. No ocurre lo mismo con aquel planteo que impide el acceso a la magistratura basado en el color de piel, ya que el color de piel no tiene relevancia alguna para el ejercicio de cualquier magistratura. O, cuando la norma impide el ejercicio de algún derecho político, en virtud del sexo de la persona, ya que el sexo de

¹ COING, *Fundamentos de Filosofía del Derecho*, cit., pág. 134.

las personas no tiene relevancia para el pleno ejercicio de los derechos políticos.

Vemos entonces que la naturaleza de la cosa va a darle a la justicia los elementos que a ésta le faltaban, para proceder a asignar con seguridad dónde corresponde plantear una desigualdad y dónde no, para que, entonces, el trato desigual no se transforme en una arbitraria discriminación.

Este intento de unificar la idea del Derecho con el eterno orden del ser, tal como lo hacemos en nuestra definición de justicia, viene desde la antigüedad.

Los estoicos lo plantearon a partir del concepto de la ley eterna, que conocida por los hombres constituye el contenido de la ley natural. Cicerón nos planteaba que la justicia es la recta razón conforme a la naturaleza. Santo Tomás también coincidía con este criterio y afirmaba: *"Lo que la justicia debe dar a cada cual, es aquello que compete a cada cual por serle atribuido por el eterno orden del ser. Todo ente y toda institución, el Estado y el matrimonio, por ejemplo, tienen su sentido natural, que les es señalado por Dios. El Derecho tiene que dar a cada cual lo que le corresponde por su naturaleza especial según el orden divino de la creación... Para Stahl, junto a la ética individual que afecta a la acción del individuo, hay una 'ética de la existencia común', que es el orden de la existencia en común de los hombres. Esta ética surge por el hecho de que las instituciones de la vida social humana, el matrimonio, el Estado, las clases sociales, tienen un fin moral inmanente que les ha sido puesto por Dios en la creación. Este orden es el 'ethos objetivo' o 'mundo moral'... es el fundamento del Derecho. El Derecho es una reproducción del orden cósmico divino, 'de la libre y divina economía del mundo'"*².

Ya hemos dicho que el conocimiento de ese eterno orden del ser es fragmentario, lo que implica nuestra absoluta imposibilidad de conocerlo en su infinita magnitud totalizadora, el hombre tan sólo accede al conocimiento de pequeñas, de ínfimas porciones del eterno orden del ser. Lo que determina, en última instancia la imposibilidad de eliminar la decisión moral en el establecimiento de una norma jurídica concreta.

Sin embargo, el conocimiento de la legalidad interna ínsita en los hechos y los procesos sociales, resulta imprescindible en la medida que se pretenda constituir un orden justo. El legislador no sólo debe conocer la técnica jurídica, el procedimiento legislativo, los antecedentes y la legislación comparada, sino que además, debe conocer los intereses y problemas que afecta la legislación que se plantea y, fundamentalmente, debe

² COING, H., *Fundamentos...*, cit., págs. 135-136.

saber y conocer acerca del comportamiento humano, y de la naturaleza misma de las cosas comprometidas en la legislación de que se trate.

Cuando no se respeta lo que surge de las porciones a las que accedemos del eterno orden del ser, se produce un fenómeno muy particular, el de obligar al hombre a reprimir sus legítimos impulsos, o vivir en la ilegalidad.

La experiencia indica que no puede regularse una conducta en forma contraria a lo que determina la propia naturaleza por un período prolongado, ya que las violaciones a la misma serán cada vez más, sin que el temor a la coacción, al eventual castigo pueda contener la realización de la conducta conforme a la naturaleza y contraria a la norma jurídica.

*"Aún más claramente —y más amenazadoramente en sus efectos sobre la vida social— se manifiesta el peligro propio de la inobservancia de la naturaleza de la cosa por el Derecho cuando el orden jurídico intenta reprimir permanentemente tendencias humanas legítimas en sí. En este caso el orden jurídico coloca permanentemente al individuo ante la elección entre renunciar a intereses importantes normalmente protegidos por el Derecho y obrar ilegalmente. Prácticamente, en una situación así el Derecho lanza siempre o casi siempre al individuo a la ilegalidad"*³.

De ello se deduce que en la medida que se desee establecer un orden justo, se debe tener en cuenta lo que surge de la naturaleza misma de las cosas, que como dijimos, viene a completar a la justicia.

Si el hombre tuviera un conocimiento pleno y acabado del orden del ser, concluiríamos aquí nuestro planteo sin más. Pero, nuevamente, nos enfrentamos a la incertidumbre y al relativismo, al comprobar que la naturaleza de la cosa nos otorga elementos, criterios de ordenación, pero no un orden cerrado y concluso, en el cual el legislador pueda observar y asignarle a cada cosa el lugar que ya tiene por serle atribuido por el eterno orden del ser. Entonces, el único camino que le queda al legislador es tomar una decisión moral a partir de los elementos conocidos del eterno orden del ser y de la valoración de los distintos puntos de vista con que se puede acceder a la materia sujeta a legislación.

Vamos a ejemplificar con una hipótesis que plantea Coing, en la que se refiere a una familia que se encuentra en una muy mala situación económica, a su vez, posee varios hijos, los que más que una alegría se transforman en una pesada carga. Ante este cuadro los padres podrían plantearse vender a uno de los hijos y con el producido de la venta mejorar la situación del resto de la familia. Desde el punto de vista estrictamente

³ COING, H. *Fundamentos...*, cit., pág. 138.

económico la solución es, al menos viable, pero resulta contrario y repugnante en todas sus partes desde el punto de vista moral. La solución para este caso, no surge inmediatamente, sino que se requiere valorar las distintas posibilidades, para entonces tomar una decisión moral basada en una determinada valoración.

La legislación sobre el divorcio es otro claro ejemplo de lo que venimos tratando. Sobre el tema existen innumerables puntos de vista, consagrados por la ley en diversas naciones, muchos de ellos contradictorios, pero además estos planteos, en su gran mayoría tienen un sustento objetivo. Algunos valoran por sobre cualquier otra cuestión la seguridad social y protección de los hijos y niegan la posibilidad de contraer una nueva unión matrimonial. Otros valoran el daño que produce a los cónyuges, a los hijos y al conjunto social el vivir una unión que ya no desean. Desde otro ángulo se plantea el desorden social que causa la disolución del vínculo; otros, consideran que debe prevalecer la autonomía moral de cada individuo sobre su vida íntima. Además de innumerables consideraciones de orden filosófico, religioso, moral, social, etcétera. Sea como fuere, el hecho es que la naturaleza de la cosa no nos da una asignación objetiva, aprehensible por el hombre, sino que en estos casos el legislador debe valorar, pesar y luego decidir.

Pese a lo dicho, creemos que el eterno orden del ser incluye en sí las valoraciones a las que hemos hecho referencia, pero, si bien las incluye, nuestro conocimiento del orden natural es limitado y sólo en la evolución, producto del decurso, el hombre perfecciona ese conocimiento, que de cualquier manera siempre será parcial. Así que, estas valoraciones subyacentes en el eterno orden del ser (es decir, que surgen de la naturaleza misma) nada agregan a lo que estamos buscando que es, precisamente, encontrar un orden natural que resuelva por sí las cuestiones sociales, sin necesidad de apelar a conceptos morales de valor. Sin embargo, si bien la naturaleza de la cosa no nos da un orden natural en las relaciones sociales, completo y cerrado, suficiente en sí mismo, nos otorga elementos ciertos de ordenación que nos permite acceder a una legitimación objetiva de aquellas situaciones a las que les corresponde un tratamiento desigual porque son naturalmente desiguales.

"La naturaleza de la cosa conduce pues a su vez a una jerarquía moral. Sólo en ésta puede hallar la justicia las escalas o criterios con que poder medir y comparar. Con ello vuelve empero a plantearse el problema del valor. La posibilidad de obtener de la idea del Derecho un contenido unívoco y positivo depende, pues, de si es posible apresar unívocamente en su contenido y en su jerarquía esos valores criteriológicos. Al mismo tiempo queda de manifiesto que, por su contenido, la idea del Derecho re-